제1편【총론】

{신의칙 template}

1. 신의칙 위배 여부 - 모순되는 거동금지

(1) 신의칙 의의 (1②)

상대방 신뢰를 헛되이 하지 않도록 성실하게 소송을 수행해야 하는 원칙. 민사소송 4대 이상 (적정, 공평, 신속, 경제)을 실현하기 위함

(2) 신의칙 내용 **(부모실남)**

소송상태 부당형성의 배제, 선행행위와 모순되는 거동의 금지
소송상 권능의 실효, 소송상 권능의 남용 금지

(3) 判例 [추완항소 부적법 주장] **(일신모피)**
[부적법한 표시정정 간과판결] **(법피본새)**
[항소권 실효] **(권신새) (길신쌍객통)**
[관할선택권 남용] **(목제남신)**

(4) 사안

제2편【소송의 주체】

제1장 법원 3개

<제척·기피·회피>

I. 제척

1. 의의: 법관이 구체적인 사건과 법률이 정한 특수한 관계에 있을 경우, 법률에 의해 당연히 직무집행에서 배제되는 것. 재판의 공정성 보장.

2. 제척이유

41조1호 **(소공공)**, 41조5호 관여: 최종변론과 판결의 합의에 관여

II. 기피

1. 의의: 제척이유 이외의 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우, 당사자의 신청에 의한 재판으로 법관을 직무집행에서 배제하는 것. 재판의 공정성 보장.

2. 기피이유 (43①) **(평불주/편공)**

{기피각하결정 확정 template}

1. 기피신청과 절차의 정지 (48)

2. 소취하 간주 정당여부

(1) 소취하 간주 요건

(2) 사안 - 48조 위반하여 쌍방불출석 효과 발생시킨 절차상 흠

3. 기피각하결정확정으로 하자 치유 여부 긍정설/부정설/절충설(判)

<관할> (법지거직사토합변)

사물관할

[병합소송에서 소가] 합산원칙

의의(27①) /내용: 수개 청구의 경제적 이익이 독립한 별개의 것
예외 **(중수부, 선예대연주)**
중복청구 흡수주의: 수 개 청구의 경제적 이익이 중복되면 중복되는 범위 내에서 흡수되고, 가장 다액인 청구의 가액을 소가로
수단청구 불산입원칙, 부대청구 불산입원칙

토지관할 (보특관경)

보통재판적: 3, 5①② 특별재판적: 7, 8후단, 11, 12, 18, 20, 21
관련재판적 (25①②)

요건 i) 하나의 소로 여러 청구 -29, 30조도 포함
ii) 2조 내지 24조 규정에 따라 한 청구에 대한 관할권有
iii) 관할권 없는 청구가 다른 법원의 전속관할X

주관적 병합에 적용여부 (개정법 65조 전문)

합의관할 (29)

요건 i) 제1심 임의관할 방식: 서면
ii) 일정한 법률관계로 특정
iii) 관할법원 특정
iv) 기타 소송행위 요건 [약관규제법] **(지건/내개거관)**

모습 [불분명] 통설(判)/소수설

효력 [주관적 범위] **(지변정)**

변론관할

요건 i) 관할권 없는 1심 법원에 소제기
ii) 피고가 관할위반이라고 항변하지 않고
iii) 본안 변론

[청구기각 답변 본안변론인지] 긍정설(多)/부정설

[진술간주 변론관할 인정여부] 判 부정

이송 (관할위반 이송, 34)

[원심법원제출주의 위반] 다수설/소수설 **(대원기/혼원기진손)**

[이송신청권 인정여부] 긍정설(李)/부정설(判) **(법이) (법당항신)**

[이송결정 기속력 전속관할 위반] 긍정설/부정설 **(불반상)**

{특허권 등 template}

1. 문제의 소재

2. 토지관할

(1) 2조~23조의 재판적

(2) 24②③ 특허권 등 지식재산권 특별재판적
관할집중을 강화하여 소송의 전문화·효율화 도모
"목포를 관할하는 고등법원이 있는 광주지방법원"

3. 이송가부

(1) 34① (관할위반에 의한 이송)

(2) 35 (편의이송): 전속관할 적용X

(3) 36③ (특허권 등 이송): 당사자 피해방지, 사법접근성 보장

<재판권>

[인적범위] 절대적/상대적 주권면제주의(判) **(사주밀부사/사)**

[물적범위 template]

1. 문제의 소재 - 국제재판관할 의의
외국적 요소가 있는 섭외사건에 대해 어느 나라 법원이 재판권을 행사할 수 있는가의 문제.

2. 국제재판관할합의 유효여부

(1) 국제재판관할 합의 요건·방식

(2) 전속적 국제재판관할 합의 요건 **(대외합공)**

1) 다수설判例
i) 사건이 **대**한민국 법원의 전속관할X
ii) 지정된 **외**국법원이 외국법상 관할권을 갖고,
iii) 사건이 외국법원과 **합**리적 관련성 iv) 합의가 **공**서양속反X

2) 소수설: 중립적인 법원으로 합의하는 당사자 의사를 존중하여 합리적 관련성 요건 불필요

3) 검토: 합리적 관련성 없는 법원이 재판하면 그 법원에게 외국법의 적용이라는 부담을 지게 해

(3) 사안 - 합리적 관련성 X

3. 국제재판관할 판단기준

(1) 종래 학설·判例
역추지설, 관할배분설이 있으나, 종래 判例인 수정역추지설은 토지관할 규정을 참작해 국제재판관할을 인정하되, 소송법상 이념에 반하는 특단의 사정이 있으면 부정했다.

(2) 개정국제사법 2조 **(실국특)**

1) 실질적 관련성: 법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 **실**질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할有

2) 구체적 판단: **국**내법의 토지관할 규정을 참작하되, 국제재판관할의 **특**수성을 고려한다. 判例 당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 결정해야 한다 (관할배분설 입장)

3) 제조물책임소송 判 **(제합제실)**
불법행위 손배 (ex 항공기추락)判
(3) 가사사건의 경우 判 **(국국분/준자소판)**
4. 사안의 국제재판관할
(1) 토지관할 규정 참작
1) 보통재판적 2, 5①② 2) 특별재판적 11 (가압류)
(2) 국제재판관할의 특수성 고려 (判例 표현으로 사안 포섭)
[가압류]判 **(생예집실)** [고엽제]判 **(예자실)**
[강제징용]判 **(피역손실)** 추가논점 217조3호判 **(식헌승)**
[청어알사건]判 **(당팩송실)**
[이혼사건]判 **(생이소집준)**
(3) 소결
[국제재판관할에서 변론관할] 判 **(30공경실)**

제2장 당사자 3개
<당사자확정> (확발간)
[공부상 오기]
1. 당사자확정: 의사설/행동설/실질적표시설(判)
2. 발견시 보정방법: 표시정정 (학설대립無) 항소심 표시정정判
3. 간과판결 효력 判 **(표잘무효확)**

[학교]
1. 당사자확정: 의사설/행동설/실질적표시설(判)
2. 발견시 보정방법: 피고경정설/표시정정설(判)
(법원의 조치-표시정정을 위한 석명 判 **(능청확표)**)

[성명모용]
1. 당사자확정: 의사설/행동설/실질적표시설(判)
2. 발견시 조치 (소제기시 원고 모용해 소 제기)
무권대리에 준해 피모용자가 소를 추인하지 않은 한 소각하판결
2. 발견시 조치 (소제기시 피고 잘못 기재)
(1) 규정 없는 임의적당사자변경 긍정설/부정설(判) **(표필/해)**
(2) 피고경정가부 - 피고경정의 의의·요건
- 잘못 지정 분명한 경우 학설/判 **(취원법법)**
→ 소 취하 후 다시 소제기 해야
2. 발견시 조치 (소송 중 피고 모용해 출석)
모용자 소송관여를 배척하고 피모용자에게 기일통지하여 기일속행
3. 간과판결 효력과 구제수단:
피모용자에게, 무권대리흠 424①4, 451①3

[제소전사망]
1. 당사자확정: 의사설/행동설/실질적표시설(判)
2. 발견시 보정방법: 피고경정설/표시정정설(判) **(실표상/오)**
상급심 표지정정 不可 (제소전 사망 예외)
(법원의 조치-표시정정을 위한 석명 判 **(능청확표)**)
3. 간과판결 효력과 구제수단: 학설/判 **(대무항수)**
+ 시효중단 효력 민170①② 判 **(무의시170)**

[제소전사망-1순위 상속포기]
1. 당사자확정
2. 발견시 보정방법: 피고경정설/표시정정설(判) **(실표상+/오)**
+ 소멸시효 논점 265

<당사자자격>
당사자능력
의의: 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력

[조합]
1. 조합과 비법인사단 구별 判 **(사조단)**
2. 조합의 소송수행방안
(1) 조합 명의: 조합의 당사자능력 긍정설/부정설(判)
(2) 구성원
1) 능동소송: 합유물(민272), 합유지분(민273) 고필
다만, 보존행위(민272단서) 통공
[공동수급체 공동소송] 원칙判 **(조/구합/1지)**
예외判 **(개지도권/구지구/묵)**
2) 수동소송: i) 조합채권자가 조합원의 개인적 책임에 기해 채권을 행사할 경우에는 조합원 각자를 상대로 소제기 可, 즉 통공 ii) 조합재산에 관해 공동책임을 묻는 청구는 고필
(3) 담당
1) 임의적 소송담당 중 선정당사자
2) 규정이 없는 임의적 소송담당
① 허용기준 判 **(변신합)** ② 합리적 필요 있는 경우 **(이지)**
③ 조합의 경우 判
(4) 대리
1) 법률상 소송대리인 2) 소송위임에 의한 소송대리인

[비법인사단]
1. 조합과 비법인사단 구별
2. 비법인사단의 소송수행방안
(1) 비법인사단 명의: 52
(2) 구성원
1) 구성원 전원 명의: 총유물(민276) 고필
2) 보존행위 判 **(명전구/공)**
(3) 담당 不可 (53)

당사자적격
의의: 특정사건에서 정당한 당사자로서 소송을 수행하고
본안판결을 받기에 적합한 자격
1. 일반적 - 이행
[당사자적격 판단기준] 통설/判 **(이청의/등말적)**
[불법점유 건물인도청구] 判 **(불현소인)**
[저당권이전 부기등기後 말소등기청구 피고적격] 判 **(승새양)**
→ 지적의무 判 **(재변각법재)**
[저당권이전 부기등기後 말소등기청구 소의이익] 判
(일직부/이무효부)
2. 제3자소송담당
(1) 법정소송담당 (병행형, 갈음형)
(2) 임의적 소송담당 [입주자대표회의] 判 **(집재집자)**

소송능력 [미성년자에 대한 송달] 유효설/무효설(判)

변론능력
{변론능력 template}
1. 문제의 소재
2. 변론능력 의의
법원에 대해 유효하게 소송행위를 할 수 있는 능력.
소송능력자는 원칙적으로 변론능력도 있다.
3. 진술금지재판받은 경우 144①②③
4. 변호사 선임명령 불응시 취급
(1) 원칙: 144④
(2) 선정당사자에게 선임명령한 경우 判 **(내의당144변)**
(3) 사안

<소송상대리인>

법정대리인

[소송상 특별대리인] (선결: 민법 64, 921 이해상반행위)

1. 의의 (62, 64준용)
   제한능력자가 당사자인 경우, 법정대리인이 없는 경우 등에서 법원에 특별대리인을 선임하여 주도록 신청할 수 있다.
2. 요건
3. 특별대리인 권한-소 제기, 상소 제기 등 특별수권 학설/判例

[공동대리원칙-모순행위 처리] 56조2항 유추설(多)/67조 준용설

[소멸통지]

1. 문제의 소재
2. 소취하 요건 만족 여부 (266)
   i) 판결이 확정되기까지 ii) 본안에 관해 응소한 경우 피고의 동의
3. 대리·대표권소멸통지와 소취하 효력
   (1) 의의 (63①본문, 64준용, 97준용, 63②준용)
   (2) 내용 判 **(알과통절대)**
   (3) 예외: 구 대표자가 상대방과 통모하여 소 취하 등의 소송행위를 해도 유효로 볼 수밖에 없어 본인에게 너무 가혹. 단서규정 신설. (4) 사안

임의대리인

[소송대리권의 범위 (90)-사법행위] 判 **(변위실)**

[개별대리원칙 (93)]

[모순행위 처리]
i) 동시에 모순되는 행위가 이루어진 경우 모두 효력이 발생하지 않는다. ii) 때를 달리 해 모순되는 행위가 이루어진 경우 앞의 행위가 철회될 수 있으면 뒤의 행위에 의해 철회되고, 앞의 행위가 철회될 수 없으면 뒤의 행위가 효력이 없다.

[여러 소송대리인에게 송달] 判 **(93180효항)**

[심급대리] 긍정설(判)/부정설

[파기환송후 항소심 대리권부활] 긍정설(判)/부정설

[보수청구시기] 원칙/파기환송시 判 **(속대소위)**

[재상고심에서 상고심 대리권부활] 判 **(심파다항상)**

[재심소송에서 재심 전 대리권부활] 判 **(신분특재)**

무권대리인

[유동적 무효와 추인 (60, 97준용) - 일괄추인 원칙]

1. 의의: 무권대리인이 행한 소송행위의 추인은 소송행위 전체를 대상으로 해야 하고 그 중 일부의 소송행위를 추인하는 것은 허용되지 않는다.
2. 내용: 일부만 선별해 추인하면 절차안정을 해하기 때문에 判例 '상고제기만 추인하고 그 밖의 소송행위는 모두 추인하지 않는다'는 일부추인은 허용하지 않는다.
3. 예외: 判例 소취하 행위만을 제외하고 나머지 소송행위를 추인함은 소송의 혼란을 일으킬 우려가 없고 소송경제상으로도 적절하여 추인은 유효하다.
4. 위반 효과: 일부추인은 무효이며, 추인하지 않은 나머지 행위도 추인거절의 의사표시를 했다면 확정적 무효가 되어 다시 추인할 수 없다.

[표현대리] 긍정설/부정설(判)

[쌍방대리]

1. 변호사법 31조 규정 고찰
   (1) 1호 사건 동일여부 판단
   判例 분쟁실체의 동일 여부로 결정되므로, 소송물 동일여부나 민사사건과 형사사건 같이 절차가 같은 성질인지는 관계없다.
   (2) 법률사무소에 준용
   법무법인 등은 물론 민법상 조합 형태로 운영되는 법률사무소에 대하여도 쌍방대리금지규정을 두었다.
2. 변호사 쌍방대리의 효력 **(이알변/소선)**
   절대무효설/유효설/추인설/이의설(判)

<권리근거규정암기>

매매계약에 기한 대금지급청구/이전등기청구 (민568)
 - 매매계약체결사실 (이행기도래사실은 요건사실 아님!)
소비대차계약에 기한 대여금반환청구 (민598)
   i) 소비대차계약체결 ii) 목적물 인도 iii) 변제기도래
소유권에 기한 인도청구 (민213)
   i) 원고의 소유 ii) 피고의 점유
소유권에 기한 말소등기청구 (민214)
   i) 원고의 소유 ii) 피고의 등기 iii) 등기의 원인무효
   - (저당권인 경우) iii) 저당권 소멸 (원인무효, 변제 등)
소유권에 기한 건물철거청구 or 퇴거청구 (민214)
   i) 원고의 토지소유 ii) 피고의 건물소유(철거) or 건물점유(퇴거)
불법행위 손해배상청구 (민750)
   i) 고의·과실 ii) 위법한 가해행위 iii) 손해 (손해액도 포함)
   iv) 인과관계

제3편【1심 소송절차】

제1장 소송의 개시와 심리대상 6개

<소>

[공유물분할의 소 template]

1. 문제의 소재
2. 처분권주의 의의
3. 공유물분할청구소송의 성질 통判 **(절청자비)**
4. 분할방법
   (1) 현물분할 방법 判 **(다금지)**
   (2) 대금분할 방법 判 **(분가경)**
   cf. [공유물분할조서 형성력 인정여부] 判 **(공협등소/판187/협)**

[경계확정의 소]

<소송요건>

소송요건 일반론

{직권조사사항 template} 이C 2회-3-3, 박B 2회-1-3

1. 문제의 소재
2. OOO 직권조사사항여부
   (1) 직권조사사항 의의
   당사자가 주장·항변하거나 다투지 아니하여도 법원이 직권을 발동하여 진위 여부를 판단하거나 법규를 적용하는 것
   (2) 대표권判 **(대소의상조)** 피보전채권判 **(피소의조)** (3) 사안
3. OOO 대한 자백 인정여부
   (1) 직권조사사항인 소송요건의 자료수집방법
   1) 학설: i) 항상 직권조사라는 제3의 방식에 의한다는 견해
   ii) 변론주의, 직권조사, 직권탐지 방식의 혼용설,
   iii) 변론주의와 직권탐지주의에 의한다는 견해
   2) 검토: 직권조사사항에는 공익적요소가 희박한 것에서부터 강한 것까지 다양하므로 변론주의, 직권조사, 직권탐지 방식을 혼용 타당. 대부분의 소송요건은 직권조사(prufung)에 의하는데 사실과 증거 제출책임이 당사자에게 있지만, 자백은 인정X
   (2) 사안

[소송요건 판단시점]
1. 원칙: 소송요건은 사실심 변론종결시를 기준으로 판단한다.
2. 예외
  1) 제소시에 갖추면 그 뒤 소멸돼도 부적법하게 되지 않는 것
    관할권, 당사자능력, 소송능력, 선정당사자 적격, 대리권
  2) 사실심 변론종결 뒤 사유 고려
    [당사자적격 회복] 判 **(압피소상)**
    [기판력 저촉 발생] 判
[소송요건 선순위성] 긍정설(判)/부정설

소의 이익
의의: 소송물에 대해 본안판결 받을 수 있는 정당한 이익
I. 권리보호자격 (소금장승신)
1. **소**구할 수 있는 법률관계
  [대장명의말소청구] 소수설/다수설(判) **(권소말/행사)**
2. 법률상·계약상 제소**금**지사유X 3. 제소**장**애사유X
4. 동일 청구에 대한 **승**소확정판결X 5. **신**의칙위반X

II. 권리보호이익
1. 이행의 소
(1) 현재이행의소
  1) 집행 불능이거나 현저히 곤란
  [순차이전등기말소청구] 判 **(후전전)**
  [가압류된 금전채권 이행청구]
    소의 이익 긍정 判 **(가집/시/배취소)**
    본안판단 - 무조건청구인용 / "제3채무자로서는 이행을 명하는 판결이 있더라도 집행단계에서 저지하면 된다."
  [가압류된 이전등기청구권 이행청구]
    소의 이익 긍정, 본안판단 - 가압류해제조건인용 **(신저조)**
  2) 목적이 실현되거나 실익이 없는 경우
    [저당권이전 부기등기後 말소등기청구 소의이익] 判 **(일직부/이무효부)**
    [효과 없는 의사진술을 구하는 청구] 判 **(판간/간소있소)**
(2) 장래이행의소
  1) 의의·취지
  변론종결시를 기준으로 이행기가 장래에 도래하는 이행청구권을 주장하는 소. 확정판결을 얻어 두었다가 이행기가 도래하면 즉시 강제집행을 할 수 있게 하려는 것.
  2) 소의 이익
  ① 청구적격: i) 청구권 발생의 기초가 되는 사실상·법률상 관계가 변론종결시에 존재하고 ii) 그 상태가 계속 될 것이 예상되어야
  ② 미리청구할 필요: 임의이행 거부 or 의무의 성질이 정기행위
  [피담보채무변제조건 저당권말소등기]
    말소청구의 기초인 저당권설정계약이 변론종결시에 존재하고, 조건성취 개연성/ 피담보채무 액수 다툼
  [불법점유 부당이득반환청구, 손해배상청구] 判 **(수확)**
    반환청구의 기초인 불법점유상태가 변론종결시에 존재하고, 인도완료일까지 불법점유상태가 계속됨이 확실 / 장래부당이득반환청구는 계속적, 반복적청구이므로 이행기 도래분 불이행한 이상 장래 이행 기대X
  [적법점유 부당이득반환청구] 判 **(사의변)**
  [채권양도통지 조건 이행청구] 判 **(대법양장)**

2. 확인의 소 (자현권법현장)
(1) 대상적격
  1) 자기의 [제3자 권리관계]
  2) 현재
    원칙: 과거 법률관계 존부 확정은 현재의 분쟁해결을 위한 직접적인 방법이 되지 못하므로 확인의 이익이 없다.
    예외 [선해-매매계약무효확인, 해제확인] 判 **(과채간)**
  3) 권리·법률관계 [증서진부확인]

(2) 확인의 이익
  4) 법률상지위
  [유치권부존재확인] 判
    ① 확인의 이익-제3자 권리관계 **(저거법유)**
    ② 유치권일부부존재확인 가부 **(전경유법/피법)**
    ③ 저당권 소멸시 **(경매유법)**
    ④ 처분권주의 **(피경일)** ⑤ 증명책임
  [담보지상권 피담보채무부존재확인] 判 **(당지지법)**
  5) 현존하는 불안
  [국가상대확인] 判 ① 미등기 토지 **(대판보)**
    ② 제3자 명의 등기 토지 **(등국법)** 법적불안정성
    ③ 미등기 건물 **(가분국법)** 법률상지위 불안제거
    ④ 국가 시효취득 완성 **(이행변국법)** 법률상이익
  6) 불안제거에 가장 유효적절
  [적극적 확인O 소극적확인X] [당해절차문제 별소제기X]
  [이행의 소에 대한 확인의 소의 보충성]
    원칙 및 예외: 이행의 소를 제기할 수 있는데도 이행청구권 자체의 존재확인을 구하는 것은 불안제거에 실효성이 없어 허용되지 않는다. 다만, 청구권의 선결적 법률관계 확인청구는 보충성에 반하지 않는다. cf. 채무부존재확인O
  [매매계약무효확인, 해제확인] 判 **(이기다즉)**
  [피담보채무부존재확인] 적법설/부적법설(判) **(피근별/선분)**
[확인의 이익 흠결시 주문기재만 잘못된 경우] 判

<소송물> :말소등기청구와 부당이득반환청구 소송물이론 누락주의!
구이론: 실체법상 권리, 일지설: 신청(청구취지)
이지설: 신청과 청구원인의 사실관계
검토: 신이론은 법원의 실무부담이 가중되고 원고의 권리구제 불리
[손해배상청구 소송물] 손해1개설/2분설/3분설(判)
[말소등기청구 소송물] 判
[진정명의회복 말소등기청구와 계약해제 말소등기청구]判**(방계원기)**
[부당이득반환청구와 계약해제 원상회복청구] 判 **(계부법공)**
[점유개시원인이 다른 취득시효완성 이전등기청구] 判
[확인의 소 소송물] 다수설(判)/소수설 **(소권변확기/증상동/성)**
[일부청구]
  의의: 가분급여를 목적으로 하는 채권을 분할해 일부만 청구
  ① 소송물: 긍정설/부정설/명시설(判) **(특별명소/분분)** 사례判
  ② 중복소제기: 부정설/긍정설/명시설(判)
  ③ 기판력: 긍정설/부정설/명시설(判) **(가나명기/분분)**
  ④ 시효중단: 일부중단설/전부중단설/절충설(判) (선결: 265)
    1) 기본적인 입장 **(일나시/나소확시)**
    2) 일부청구 명시했지만 청구취지확장 뜻 명백히 한 경우
  ① 청구금액 확장한 경우 **(일진종소전)**
  ② 청구금액 확장하지 않은 경우 **(나계최174나)**
  ⑤ 과실상계: 안분설/외측설(判)/절충설

cf. 공격방법이 다른 때 (말부취소대)
  ①말소등기청구-등기의 무효사유, ②부당이득반환청구-법률상원인없는사유(취소, 무효..) ③채권자취소권-피보전채권 ④소유권확인소-소유권취득원인 ⑤-유권대리,표현대리,추인

<재판장의 소장심사와 그 후 조치>
I. 재판장의 소장심사
1. 소장심사의 대상
2. 보정명령 (254①, 402①)과 불복
(1) 소송대리인에 대한 보정명령 가부 判 **(심상/인소재인)**
(2) 보정의 효력 발생시기 보정시설/소장제출시설
(3) 보정명령에 대한 불복불가
통상항고 가부: 判 **(인439불특/인독)**
특별항고 가부: 449조의 특별항고에서 말하는 결정·명령은 독립된 재판이어야 하는데, 인지보정명령은 중간적재판이므로 특별항고의 대상도 아니다.
3. 소장각하명령 (254②, 402②)과 불복
(1) 소장각하명령 행사시기 소장부본송달시설(判)/변론개시시설
[독립당사자소송 각하명령 행사시기] 判 **(피항재)**
(2) 각하명령 성립 후 보정가부
각하명령 효력발생 후 보정가부 判 **(각각즉인하)**
각하명령 성립 후 보정가부 判 **(각성고인/각위재)**
II. 답변서제출과 무변론판결 (257①②)

<소제기 효과 - 중복소제기>
[소송계속 발생시기] 소장부본송달시설(判)
1. 의의: 법원에 계속 중인 사건에 대해 당사자는 동일한 소를 제기할 수 없다. 판결의 모순·저촉을 방지
2. 요건
1) 당사자 동일 [대위소송] [추심소송]
2) 소송물 동일
[상계항변] 긍정설/부정설(判)/변론중지설 **(모경별상/기권)**
[청구권확인/이행] **(취원중원/상모각)** [확대시도]
3) 전소 계속 중 후소제기
[국제적중복소송] 규제소극설/승인예측설(判)/
권리보호이익설/비교형량설 **(외217소/모이)**

<채권자대위소송, 추심소송, 채권자취소소송 논의>
I. 채권자대위소송 (101)
1. 법적성질: 법정소송담당설(判)/고유의 대위권설
2. 적법요건
담당설의 입장에서 i) 피보전채권 ii) 보전의 필요성 iii) 채무자의 권리불행사 흠결시 당사자적격 흠결로 소 각하하고,
iv) 피대위권리는 소송물로 본안의 문제이므로 흠결시 청구기각
(고유의 대위권설의 입장에서는 모두 실체법상 요건사실이므로 흠결시 청구기각)
(1) 피보전채권
(2) 보전의 필요성
[금전채권자 공유물분할청구권 대위행사]判 **(책현자부보/전현/지)**
(3) 채무자의 권리행사
[원칙] 判 채권자가 대위권을 행사할 당시에 이미 채무자가 권리를 행사했을 때는 채권자가 채무자의 권리를 대위행사할 당사자적격이 없다.
[각하판결] 判 [소취하] 학설判 **(합청부)**
3. 중복소제기
[대위소송 중 채무자 소제기] 긍정설(判)/절충설/부정설 **(대실/모)**
[대위소송 중 다른 채권자 소제기][채무자 소송 중 대위소송제기]
4. 재소금지 [피대위자] 긍정설(判)/부정설 **(대피종피/담)**
[피보전채권 인낙한 채무자] 判 **(대적인채)**
5. 기판력
6. 시효중단
[시효중단 효력 유지여부] 判 **(동특잠)** 선결: 265
(채권자대위소송 중 피대위권리 양수하여 소 변경)
[순차대위소송] 判 선결: 민170①②

II. 추심소송
1. 당사자적격
1) 압류·추심명령 송달 유효한 경우 判 **(압3추채)**
2) 압류·추심명령 송달 무효인 경우 判 **(3적채)**
3) 압류·추심명령 신청취하 判
2. 중복소제기
[채무자 소송 중 추심소송제기]
判다수**(이경모/상압참/압채중)** 判소수 **(부소중/압참)**
3. 재소금지
[다른 채권자] 判
4. 기판력
[추심소송 기판력이 다른 채권자에게 미치는지]
① 추심소송에서 '청구 포기'의 의미 判 **(피포처별)**
② 기판력 확장여부 判 **(추압소당)**
5. 시효중단
[시효중단 효력 유지여부] 判 선결: 민170①②
(채무자 각하판결 후 6개월 내 추심소송제기)
① 압류·추심명령 받은 채무자 시효중단 효력 判 **(이권추추)**
② 시효중단 효력 유지 여부 判 **(갈각추재유)**

III. 채권자취소소송 (P71)
1. 법적성질과 피고적격 형성소송설/이행소송설 **(사책집/원)**
2. 중복소제기
[다른 채권자가 취소소송] 判
[같은 채권자가 취소소송] 判 **(사법공소)**
3. 기판력
[취소소송 확정판결 효력이 다른 채권자에게 미치는지] 判
[확정판결로 마쳐진 등기 사해행위로 말소] 判 **(사원법/확원효)**
4. 소의 이익 **(승권/승재중권)** (선결: 기판력 논점)
1) 승소판결 확정시 2) 재산이나 가액 회복시
5. 피보전채권 교환·추가 判 **(피공소/피동참)**

제2장 변론 5개
<심리원칙>
처분권주의 (203)
{일부인용 template}
1. 문제의 소재
2. (OO이행판결) 처분권주의 위반여부
(1) 처분권주의 의의 (203) **(절당/사)**
(2) 처분권주의 내용 判 - 일부인용판결로서 OO이행판결
(3) 사안
3. OO이행판결 요건 **(피원미)** (각 요건별로 바로 사안포섭)
(1) **피**고 항변이 이유 있을 것 (2) **원**고가 반대 의사표시 하지 않을 것 (3) **미**리 청구할 필요 등 장래이행의 소 요건 충족

[단순이행청구 상환이행판결]
[동이항, 유치권] 처분권주의 내용判 **(매소미상)** 반대 의사표시判
[건매청]
① 건물철거청구에 상환인도청구 포함여부
긍정설/부정설(判) **(건매/취원석)**
② 석명의무 위반여부
(1) 석명권 의의 (136①) **(분질/변)**

(2) 적극적 석명 가부
제한적긍정설(判)/부정설 **(요공변석/대임지/합경의난공승)**

[단순이행청구 선이행판결]
[피담보채무전부변제 저당권말소등기]
처분권주의 내용判 **(피잔잔)** 반대 의사표시判
"피고는 원고로부터 5000만원 지급받은 다음, 원고에게 A토지 저당권말소등기절차를 이행하라. 원고의 나머지 청구를 기각한다"
[선이행청구 더 불리한 선이행판결]
[피담보채무변제조건 저당권말소등기]
① 장래이행의 소 적법여부 ② 처분권주의 내용判 **(피잔잔)**
(사실 단순이행청구에 대해 선이행판결 하는 경우 등도 장래이행판결 하는 것이므로 단순이행청구에 장래이행청구가 포함되어 있다고 보고 장래이행의 소 적법여부를 따져줘야 하는데, 선이행판결 요건에서 간단하게 검토하는 것이 가능한 듯 - 곽B 문제)

[일시금청구에 대해 정기금판결] 判 **(자/어일정불일)**
[집행불능·이행불능 대상청구] 判

변론주의 ↔ 직권탐지주의
{주장책임 template - 변론주의 위반여부}
1. 문제의 소재
2. 변론주의 의의·내용 **(소당/사자증)** [주장공통원칙] 判 **(주쌍불)**
3. 변론주의 대상이 되는 주요사실
(1) 주요사실과 간접사실 구별 **(법요추)**
(2) OO 사실 주요사실여부
[소멸시효기산점] 통설(判)/소수설 **(소본변/예)**
[소멸시효기간] 判 **(어단변)**
[취득시효기산점] 주요사실설/간접사실설(判) **(법당/안)**
[점유권원] 判 **(자당)**
[수입, 가동연한, 공제할 생활비] 判
4. 소송자료와 증거자료 구별과 완화
(1) 구별
주장하지 않은 주요사실은 그 사실이 증거조사에서 밝혀져도 법원은 이를 고려할 수 없다.
(2) 완화 (ex 간접적 주장 인정여부)
[간접적 주장] 긍정설(判)/부정설 **(명간/구실)**
[묵시적 주장] 포함인정 判 **(본채원채본)**
포함부정 判 **(표요유/요)**
포함부정 判 **(동소채원)**
[가정적 항변] 判 **(원석내이)**

{과실 - 주장책임, 자백구속력 template} 심3회-1-1
1. 문제의 소재
2. 변론주의 의의 or 자백 의의 및 요건
3. 주요사실과 간접사실 구별
(1) 법규기준설 **(법요추)**
but 주요사실이 인과관계, 과실처럼 민법상 일반조항인 경우, 직접증명이 곤란하여 간접사실에 의해 그 존재를 추단할 수 밖에 없으므로 뜻밖의 재판
(2) 신설 기준재구성설, 준주요사실설
(3) 검토: 명확한 구별 기준을 제시한 법규기준설 타당. 다만, 과실은 가치판단의 결론일 뿐이므로 판단의 기초가 되는 구체적 사실이 주요사실이 된다고 보아야.
4. 사안해결

{응소행위와 시효중단사유 주장책임 template}
1. 문제의 소재
2. 응소행위가 시효중단사유인지
긍정설(判)/부정설 **(시소응적받/근)**
3. 시효중단사유 주장요부
(1) 변론주의와 주장책임 의의
(2) 변론주의 대상이 되는 주요사실
(3) 소송자료와 증거자료 구별과 완화 (4) 사안 判 **(변응시)**
4. 석명의무 위반여부
(1) 석명권 의의 (136①) **(분질/변)**
(2) 적극적 석명 가부 **(요공변석/대임지/합경의난공승)**
(3) 사안 判 **(시응석)**

{표현대리사실 주장책임 template}
1. 처분권주의 위반 여부
구이론을 취해도 유권대리사실과 무권대리사실은 소송물을 식별하는 청구원인이 아니고 단순한 공격방어방법 처분권주의 위반X
2. 변론주의 위반 여부
(1) 변론주의와 주장책임 의의
(2) 변론주의 대상이 되는 주요사실
1) 주요사실과 간접사실 구별
2) 사안: 유권대리사실, 표현대리사실 모두 주요사실
(3) 유권대리주장에 표현대리주장 포함여부
문제점 - 소송자료와 증거자료의 구별과 완화
불포함설(判)/포함설 **(표요유/요)**
3. 석명의무 위반여부
(1) 석명권 의의 (136①)
(2) 학설: i) 불포함설의 입장에서 원고에게 표현대리주장까지 하는 것인지 석명권을 행사해야 한다는 견해와 행사 의무가 없다는 견해 ii) 포함설의 입장에서 피고에게 원고의 악의·과실에 대한 방어를 행하도록 석명해야 한다는 견해
(3) 判例
(4) 검토: 당사자의 법률지식이 향상된 점과 공평을 고려

{지적의무 template}
1. 문제의 소재
2. 지적의무 의의 (136④) **(간의/예)**
(1항과의 관계: 1항의 석명권과 달리 청구나 항변 자체의 근거인 법적관점이라는 견해가 있으나, 1항의 석명권의 법률적 측면에서의 강화로 볼 것)
3. 지적의무 요건
i) 당사자가 간과하였음이 분명 ii) 법률상 사항
iii) 판결의 결과에 영향
4. 지적의무 행사 방식
불이익을 받을 자에게 의견진술기회를 주는 것이며
법원이 자신의 견해를 밝힐 필요는 없다
5. 사안해결
[간과한 소송요건] **(적기익부취)**
[당사자**적**격], [제소**기**간], [확인의 이**익**] 判 **(현과석/의취익)**
[**부**제소합의], [청구**취**지불특정]
[불법행위, 채무불이행 불명시 불법행위로 판단] O 이B 4회-2-1
[사용자책임 묻는데 환경정책기본법상책임 인정] O
[소유권에 기한 인도청구에 대해 대위청구 판단] △ (O)
[대위소송 보전의 필요성]
① 대위소송 법적성질 및 적법요건
② 대위소송 각하 정당여부

(1) 判例 **(시말상보)** (2) 사안
3 주장이 없는 피보전채권 직권 인정 요부
(1) 직권조사사항인 소송요건의 자료수집방법
(2) 判例 원고가 피보전채권으로 주장하지 아니한 권리까지 피보전채권이 될 수 있는지 판단할 필요가 없다.
(3) 사안: 주장이 없는 상속지분 초과부분을 직권으로 인정할 수 없다. 다만, 초과부분에 대해 지적해야 하는지 문제된다.
조 지적의무 위반 여부
(1) 지적의무 의의 (2) 요건 (3) 행사방식
(4) 사안: 判例표현으로 포섭 **(상보석보석)**

[소변경 진명등]
1 석명의무 위반여부
(1) 석명권 의의 (136①)
(2) 석명의무 - 상고이유 여부
1) 학설 긍정설/부정설 2) 검토
(3) [소변경 형태 불명확] 判例 소변경 형태가 불명할 경우 법원은 청구변경의 취지가 교환적인가 추가적인가에 대해 석명으로 밝힐 의무가 있다.
(4) 사안: 석명하지 않으면 심리가 현저히 조잡하게 되므로 석명권 불행사의 위법이 있다.
(5) 보론 - 지적의무
2 甲 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구 가부
(1) 判例 **(표법말진)**
(2) 사안: 甲이 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구를 할 수 없다고 판단한 것 자체는 잘못이 아니다.
3 지적의무 위반여부
(1) 지적의무 의의 (2) 요건 (3) 행사방식
(4) 사안: 判例표현으로 포섭 **(종진주진소)**

<변론>
I. 변론의 내용
[주장 순서 구속여부] **(예분기/상기출무)** (K45)
(cf. 청구 순서에는 구속됨)
[상계항변에 대한 상계재항변 불허] **(배이대/추별)** (P56-2)
{부인과 항변 template}
1. 문제의 소재
2. 사안의 주요사실 검토
3. 피고 乙 진술의 성격
(1) 부인과 항변 의의·구별기준 (2) 사안
4. OO 사실 인정여부
(자백, 자백간주, 현저한 사실 해당하는지 검토 or 증명책임)
(1) 증명책임 의의 (2) 분배기준 (3) 사안

II. 소송상 형성권 행사 법적성질 **(수상실/사기분상)**
병존설(해제判)/소송행위설/신병존설(상계判)/양성설

III. 소송상 합의 (ex 부제소계약, 소취하계약)
1. 의의: 특정소송에 대해 법효과 발생을 목적으로 행하는 합의
2. 적법성 **(처변예합)**
3. 법적성질 및 효과 **(약의항/직종/강권/규우)**
[민법 취소가부] 判
[조건부 소취하합의] 判 [묵시적 합의해제] 判

IV. 소송행위 취소와 철회
{소송행위 취소와 철회 - 소취하 template}
1. 문제의 소재
2. 당해절차에서의 구제방법
(1) 소취하효력 다투는 방법
(2) 민법 유추적용 취소가부
1) 문제점-철회의 제한
여효적 소송행위는 절차안정과 상대방 신뢰보호를 위해 철회할 수 없음이 원칙이다
2) 학설 하자불고려설(判)/고려설 3) 判例 4) 검토 5) 사안
[사무원의 착오] 判 **(표착/착전무)**
(3) 재심규정 유추적용 철회가부 **(형유의451/형강/남)**
1) 학설 유죄확정판결필요설(判)/불요설(多)
2) 判例 3) 검토 4) 사안
(타인 유죄판결 확정 & 의사 없이 외형만 존재 요구. 따라서 사기(기망), 착오로 의사가 존재하는 경우 재심규정 유추적용X)
3. 별소제기에 의한 구제방법
(1) 기일지정신청 없이 별소제기 - 재소금지 可
(2) 기일지정신청 후 별소제기 - 중복소제기 O

[인낙-민법유추적용 취소가부]
문제점-철회의 제한
하자불고려설(判)/고려설 **(형인직간/준)**

<결석>
I. 결석 요건 (필적불) i) 필요적 변론기일 ii) 적법 기일통지
iii) 불출석 또는 출석무변론
II. 양쪽 당사자 결석 - 소 취하간주=쌍불취하 (268)
1. 의의: 양쪽 당사자가 필요적 변론기일에 적법한 기일통지를 받고도 2회 내지 3회 불출석하거나 출석무변론한 경우 취하간주
2. 요건
1) 양쪽 당사자의 1회 결석
재판장은 다시 변론기일을 정해 양쪽 당사자에게 통지
2) 양쪽 당사자의 2회 결석
법원은 변론종결하지도 않고 신기일 정함도 없이 기일 종료
3) 1월내 기일지정신청 없거나 양쪽 당사자의 3회 결석
단속적이어도 무방하나, 동일심급·동종기일
[변론기일과 변론준비기일 동종] 긍정설/부정설(判) **(일비적/재명)**
[상고대상 여부] 判 **(항요재종)**
III. 한쪽 당사자 결석
1. 진술간주 (148①)
요건 i) 서면제출 ii) 불출석 또는 출석 무변론
[재판상자백여부] 재판상자백설(判)/자백간주설 **(자변진/출)**
[서면에 의한 인낙 가부] 긍정설/부정설(종래判) **(인진변)**
개정법 (148②) "공증사무소 인증"
2. 불출석 자백간주 (150③)
요건 i) 공시송달이 아닌 적법한 기일통지
ii) 서면부제출 iii) 불출석

<기일·기간 및 송달>
추후보완
1. 추완항소 의의 (173)
2. 추완항소 요건
1) 불변기간 도과
2) 당사자가 책임질 수 없는 사유
원칙判 [공시송달] **(처진의알)**
예외判 [교도소 수감 등] [주소변경신고 간과]

3. 추완항소 절차
(1) 추후보완 기간
장애사유가 없어진 날부터 2주 이내.
사유가 없어질 당시 외국에 있던 자는 30일 이내.
判例 공시송달의 경우, 단순히 판결이 있었던 사실을 안 때가 아니고, 판결이 공시송달 방법으로 송달된 사실을 안 때.
(2) 추후보완신청
[항소를 추완항소로 보는 경우] 判 **(취주증처)**

송달
[교부송달]
[법인에 대한 송달]
원칙: "대표자의 주소, 거소에 함이 원칙이고, 법인의 영업소나 사무소에도 할 수 있다"
判例 **(법이대보)**
[타인을 통해 본인에게 전달된 경우]
"영업소 직원이 피고 주소지에 일시 방문했다가 판결정본을 수령해 피고에게 전달한 경우, 전달한 때 송달이 유효하게 된다"
"피고가 송달받을 판결정본을 원고가 받아서 원고의 처를 통해 피고의 처에게 다시 피고의 처가 피고에게 전달한 경우, 송달은 무효이다"

[보충송달 template]
(주소, 영업소, 사무소 - 동거인, 피용자, 사무원 186①)
근무지 - 사용자, 피용자 186②)
1. 문제의 소재
2. 甲에게 보충송달 유효여부 (주소 등 보충송달)
(1) 교부송달 원칙과 보충송달 (178①, 183①, 186①)
(2) 보충송달 요건
i) 주소 등 송달할 장소 "법에서 정한 송달장소에서만 허용"
ii) 송달받을 사람을 만나지 못한 때
iii) 동거인으로서 사리분별지능 있는 사람
[동거인] "같은 세대에 속하여 생활을 같이 하는 사람으로서 반드시 법률상 친족관계에 있어야 하는 것은 아니다"
[피용자, 사무원] "반드시 고용관계가 있어야 하는 것은 아니고, 평소 본인을 위하여 사무를 보조하는 자이면 충분하다"
[경비원] 경비원은 피용자, 사무원은 아니지만 "우편물의 수령권한을 명시 또는 묵시적으로 위임한 경우에 수임자가 서류를 수령함으로써 본인에게 적법하게 송달된 것으로 본다"
[사리분별지능]
"송달받을 사람에게 교부할 것을 기대할 수 있는 정도 능력"
[이해상반 수령대행인] 判 **(상전쌍보)**
[쌍방 동일한 수령대행인] 判 **(동대전쌍보)**
(3) 判例
(4) 사안: 유효 or 무효
(보충송달 동거인에게 교부된 때 송달의 효력 발생)

2. 甲에게 보충송달 유효여부 (근무지 보충송달)
(1) 교부송달 원칙과 보충송달 (178①, 183①, 186②)
(2) 보충송달 요건
i) 주소 등 송달장소에 송달할 수 없을 때 ii) 근무지에서
iii) 송달받을 사람을 만나지 못한 때
iv) 사용자, 피용자 등 사리분별지능 있는 사람
(3) [근무지 판단] 判 **(경법영근)**
(4) 사안: 유효 or 무효
3. 甲 구제방법 (송달 유효: 추완항소, 재심)
3. 송달하자 이의권 상실로 치유여부 (송달무효: 통상항소)
(1) 이의권 상실 의의·요건 (151조)
i) 소송절차에 관한 규정에 어긋난 경우
ii) 임의규정에 어긋난 경우
iii) 알거나 알 수 있었을 경우 바로 이의하지 않았을 것
(2) 判例 불변기간인 항소제기기간에 관한 규정은 강행규정이니만큼 그 기산점이 되는 판결정본의 부적법한 송달의 하자는 이의권의 포기·상실로 치유될 수 없다.
(cf. 소장, 변론기일통지서 송달의 하자는 이의권 상실 인정됨)
(3) 사안: 甲이 판결정본 송달 사실을 알면서도 항소제기를 하지 않아도 이의권은 상실되지 않는다.

[유치송달] 186③ '서류를 송달받을 사람' 또는 '주소 등에서 보충송달의 규정에 의해 서류를 넘겨받을 사람': 명문 규정상 근무장소에서 보충송달 받을 사람이 거부하면 유치송달 不可

[공시송달 template]
1. 문제의 소재
2. 甲에게 공시송달 유효여부
(1) 공시송달 의의·취지 (194): 원활한 소송진행
(2) 요건
1) 주소, 근무장소를 알 수 없는 경우: 폐문부재 또는 장기 출타로 인한 수취인부재의 경우 공시송달 할 수 없다.
2) 법인에 대한 송달: "대표자의 주소, 거소에 함이 원칙이고, 법인의 영업소나 사무소에도 할 수 있다" **(법이대보)**
(3) 부적법한 공시송달 효력 判 **(재요명요명)**
cf. 송달 일반의 무효사유
절차중단 중 망인에 대한 공시송달, 대표자 사망 후 새 대표자가 정해지지 않은 때 법인에 대한 공시송달은 무효
(4) 사안
3. 甲 구제방법 (송달 유효: 추완항소, 재심)
3. 송달하자 이의권 상실로 치유여부 (송달무효: 통상항소)
3. 쌍방불출석 취하간주 적용여부
(1) 공시송달 적법한 경우 判 **(주2공책)**
(2) 공시송달 부적법한 경우 判 **(주재적효변)**

<소송절차의 정지-중단> (법인합병=사람 사망)
(유의사항: 판결정본 송달되어도 확정 안 되면 계속 중, 변종 후 중단 중 판결선고는 적법유효하고 중단간과판결X, 공시송달 송달 일반의 무효사유와 연결가능)
[소송절차 중단]
i) 소송대리인이 없으면, 당사자 사망시 절차중단 (233) (+ 중단 중 판결선고할 수 있고 (247①), 절차는 판결선고와 동시에 중단)
ii) 소송대리인이 있으면, 절차중단되지 않으나 (238) 심급대리 원칙상 상소제기의 특별수권이 없으면 판결정본송달로 절차중단
상소특별수권 無: 판결송달-절차중단-상소기간진행X-확정X
상소특별수권 有: 판결송달-절차중단X-상소기간진행-확정
[당연승계] 긍정설(判)/부정설 **(대소지대/238)**
[수계신청] 원심법원설/선택설(判) **(수상상수/경편)**
[간과판결 효력] **(관무대/대)** - 424①4호, 451①3호

[소송대리인위임後 제소전사망] 判
소의 적법 **(당소소시)** / 절차중단 / 중단 중 상소와 하자치유

심4회-3-2, 구A 4회-3-2 ,이 사례 3-18-1A

{소송 중 사망, 상소특별수권 소송대리인 有, 상속인 C,D 누락}
1. 문제의 소재
2. 절차 중단여부 3. 당연승계여부
4. 판결의 효력
(1) 判例 **(전망잘)** (2) 사안: 판결의 효력은 C,D에게도 미친다
5. C,D 판결확정여부 (대리인이 A,B에 대해서만 항소)
(1) 공동상속인 소송형태 - 통공 (2) 심판방법
(3) 判例 **(잘합전)** (4) 사안 - 확정X
5. C,D 판결확정여부 (A,B가 항소하고 C,D는 항소기간 도과)
(1) 공동상속인 소송형태 - 통공 (2) 심판방법
(3) 判例 누락된 상속인의 상속지분부분은 그들이나 대리인이 항소하지 않으면 항소기간도과로 판결이 확정된다
(4) 사안 - 확정O

(6. 누락상속인 C,D 구제책)
(1) 문제점
(2) 학설: i) 상소제기의 특별수권을 예문으로 해석하자는 견해
ii) 누락상속인에 대해 '사실상' 절차가 중단되고 절차가 분리되어 재판의 누락이 있다고 보자는 견해
(3) 검토: 학설은 지나친 의사해석, 법률해석이므로 누락상속인에 대한 판결은 확정되는 것이고 추후보완상소, 손해배상으로 해결

제3장 증거 4개
[위법수집증거 증거능력]
문제점 - 증거능력 의의
증거조사의 대상이 될 수 있는 자격. 민사소송에서는 원칙적으로 증거능력 제한이 없다. 통신비밀보호법에 따라 제한되는지 문제.
긍정설/부정설/절충설(判) **(자위/실인단인)**

<불요증사실> (288)
I. 재판상 자백
1. 의의: **변**론 또는 변론준비기일에서 상대방 주장과 **일**치하고 자기에게 **불**리한 주요**사**실에 대한 진술
2. 요건
1) 구체적 사실을 대상 [선결적 법률관계] **(소권법동/소전소/요)**
2) 상대방 주장사실과 일치 [선행자백]
3) 자기에게 불리한 진술
증명책임설/패소가능성설(判) **(등증등자원/자)**
4) 주요사실을 대상 [간접사실] 긍정설/부정설(判)
[진정성립] 긍정설(判)/부정설 **(보주철인날/심신)**
[불확정개념 판단의 기초사실] [준거법 합의사실] 判
3. 효과 **(288법당)**
(1) 288조 불요증사실
(1) **법**원 구속력 O: 사실인정권 배제
(2) **당**사자 구속력 O (자백 철회가부)
1) 자백 철회방법 判 **(명배묵)**
2) 자백 철회의 제한
여효적 소송행위는 절차안정과 상대방 신뢰보호를 위해 철회할 수 없음이 원칙이다
3) 자백 철회 제한의 예외 **(5동착경)**
i) 5호 재심사유 ii) 상대방 동의 判 **(이동착/이동)**
iii) 자백이 진실에 반하고 착오 (288단서) 判 **(반추/부변인)**
iv) 경정권 행사 (94)

{선행자백, 진술간주 template} 이C 8회-2-2
1. 문제의 소재
2. 재판상 자백 성립여부
(1) 재판상 자백 의의·요건
(2) 상대방 주장에 일치
1) 문제점: 일방이 먼저 불리한 진술하는 것도 가능
2) 상대방 원용 후 처리 判 **(선자원일)**
재판상 자백의 효력이 발생하므로 당사자와 법원 구속
3) 상대방 원용 전 처리 判 **(일선자원철)**
다만, 원용 전에도 법원은 구속
(3) 자기에게 불리한 진술 증명책임설/패소가능성설(判)
(4) 사안
3. 자백의 방식 충족여부
진술간주 재판상자백설(判)/자백간주설
4. 자백의 효과
(1) 자백 철회방법 (2) 자백 철회의 제한 (3) 예외

II. 자백간주
1. 자백간주 성립사유
(1) 상대방 주장사실 명백히 다투지 않은 경우 (150①)
[청구원인사실 부인하는 답변서 제출한 경우] 判
[청구기각판결만 구한 경우] 判
(2) 불출석 자백간주 (150③)
i) 공시송달이 아닌 적법한 기일통지
ii) 서면부제출 iii) 불출석
[자백간주 후 공시송달] 判 **(효공효자배)**
[공시송달 후 자백간주] 判 **(공기다공다)**
(3) 답변서 부제출 자백간주 (257①②)
1) 의의·취지: 256조 1항 답변서를 제출하지 않은 경우 등에는 청구원인사실을 자백한 것으로 보고 변론 없이 판결할 수 있다. 소송촉진을 위함이다.
2) 요건 및 예외
i) 30일이내 답변서 제출하지 않거나 자백하는 취지 답변서 제출하고 항변 제출하지 않을 것, ii) 판결선고기일 통지했을 것 iii) **공**시송달 사건 (256①단서), **직**권조사할 사항이 있거나 **판**결선고 전 피고가 다투는 취지 답변서 제출한 경우 (257①단서) 무변론판결 할 수 없다.
[무변론청구기각 판결 가부] 긍정설/부정설(判)
2. 효과: **(288법당)**
288조 불요증사실, **법**원 구속력 O, **당**사자 구속력 X

III. 현저한 사실
1. 법원에 현저한 사실 의의 判例 다수/소수의견 **(직명기/직명)**
2. 현저한 사실 소송법적 의의
(1) 주장책임 O 判例 법원에 현저한 사실이라도 당사자가 그 사실에 대한 진술하지 않는 한 법원은 사실인정의 자료로 할 수 없다
(2) 자백 구속력 X
(3) 불요증사실 (288)
3. 구체적 예
(1) 연령별 기대여명 判 O
(2) 확정판결이유 구성사실 判 **(판확채합현)**

<증거조사 개시와 실시>
증거조사 개시
[모색적 증명]
1. 의의 **(증입증)**
2. 허용여부 부적법설/제한적긍정설

[유일한 증거]
1. 의의 (290단서)
증거채택여부는 법원의 재량이지만, 증거가 당사자가 주장하는 사실에 대한 유일한 증거인 때는 그러하지 아니하다. 유일한 증거는 특정 **쟁**점에 대하여, **전** 심급을 통관하여, **이**미 조사한 바가 없는 경우 **(쟁전이)**
2. 내용 - 적용범위 **(주본당)**
3. 예외 **(부시장)**
증거신청 자체가 **부**적법한 경우, **시**기에 늦은 경우, 조사가 힘든 **장**애가 있는 경우 등은 조사할 필요가 없다.
4. 위반 효과
유일한 증거임에도 조사하지 않으면 채증법칙 위반으로 상고이유

증거조사 실시
I. 증인신문
II. 감정 - 감정결과 채택
[원칙-자유심증에 따른 판단] 判 **(증자다)**
[당사자 원용 없는 경우] 判 **(현변원)**
[상반된 감정결과의 경우] 判 **(어자논)**
[일부 오류가 있는 경우] 判 **(오모일나)**

III. 서증
{판결서 실질적 증거력 template}
1. 문제의 소재: 판시내용대로 인정은 실질적 증거력 인정한 것
2. 판결서의 형식적 증거력
(1) 의의 (2) 사안 - 공문서는 진정성립 추정 (356)
3. 판결서의 실질적 증거력
(1) 의의
(2) 판결이 있었다는 사실을 증명하는 처분문서성
판결서는 그 판결이 있었다는 사실의 증명에 이용될 수 있다.
(3) 판결에서 판단한 사실을 증명하는 보고문서성
1) 문제점: 판결서가 판시내용대로 사실이 있었는지 증명하는 증거가 될 수 있는지 논란. 인정하면 보고문서로 이용되는 것
2) 判例 다수의견 **(판증보자사)** 3) 判例 소수의견 4) 검토
(4) 증거효와의 관계
判例 이미 확정된~ 이는 판결서의 보고문서성을 전제로 한다.
(4. 확정판결이유 구성사실이 현저한 사실인지)
(1) 법원에 현저한 사실 의의 **(직명기)**
(2) 현저한 사실의 소송법적 의의 (3) 判例 **(판확채합현)**

{형식적증거력 template}
1. 문제의 소재
2. 형식적 증거력 의의
문서가 증거신청당사자에 의해 작성자로 주장되는 자의 의사에 기해 작성된 것을 문서의 진정성립이라 하고, 진정성립된 문서를 형식적 증거력이 있다고 한다.
3. 형식적 증거력 판단
i) 문서의 진정성립에 관해 상대방이 성립인정, 침묵으로 답변시, 재판상자백·자백간주의 법리가 적용된다. ii) 진정성립에 관해 상대방 부인·부지로 답변시, 문서제출자가 증명책임 지지만 (357) 2단의 추정이 이용된다.
4. 형식적 증거력 추정
判例는 인영의 진정이 인정되면 날인의 진정이 사실상 추정되고, 날인의 진정이 인정되면 문서의 진정성립이 358조에 의해 유사 추정된다는 2단의 추정을 인정한다.
5. 날인의 진정 추정 복멸 (1단계 추정 복멸: **도**용, **강**박, **자**격모용)
(1) 도용의 항변 判 **(날작사/인다반/인의)**
도용사실의 증명은 간접반증으로서 그 사실 자체는 확신 줘야
(2) 재항변 判 **(인날작/문날작위)**
5. 진정성립의 추정 복멸 (2단계 추정 복멸: **변**조, **백**지문서)
[진정성립 추정 복멸방법] 반증설(判)/본증설
(1) 문제점 - 백지문서의 항변
358조는 사실상추정을 명문화한 것에 불과해 다투는 자가 반증으로 의심을 품게 하는 사정을 입증하면 추정이 번복된다
(2) 백지문서 증명시 진정성립 추정 깨지는지
1) 추정이 깨진다는 입장 判 **(작날백/백작보)**
2) 추정이 깨지지 않는다는 입장 **(보완)**
3) 검토: 백지문서를 제3자가 보충한 경우는 경험상 문서의 진정성립에 의문이 있는 경우가 많으므로 추정이 깨진다. 백지문서에 제3자가 보충기재한 사실의 증명은 간접반증으로서 그 사실 자체는 확신 줘야 한다.
(3) 재항변 判 **(진백/문기작위)**

{실질적 증거력 template}
1. 문제의 소재 진정성립 인정되면 실질적 증거력 인정해야 하는지
2. 실질적 증거력 의의: 계쟁사실을 증명할 수 있는 능력
3. 실질적 증거력 판단: 인부절차에 따라 판단하는 것이 아니라 오로지 법관의 자유심증에 일임
3. 실질적 증거력 추정
처분문서는 형식적 증거력이 인정되면 문서에 기재된 대로의 법률행위가 존재한다는 실질적증거력이 사실상 추정된다.
추정에 의해 법관의 자유심증은 제한된다.
4. 복멸: 사실상 추정은 반증으로 복멸될 수 있다. 判 **(진반기합)**

[사본제출 형태]
1) 원본에 갈음하여 제출한 경우 (원본을 믿어달라) 判 **(존진대사)**
2) 원본으로 제출한 경우 (사본 자체를 믿어달라) 判 **(독존진사)**

[문서제출명령]
1. 의의 (343조후단) **(제/증)**
2. 대상
(1) 당사자와 문서 사이에 특별한 관계 (344①)
1) 인용문서(1호) [의의] 判 **(증자근보)** [제출거부 가부] 判
2) 인도·열람문서(2호)
3) 이익·법률관계문서(3호)
(2) 개정법상 일반적 제출의무로 확장 (344②)
344조1항의 문서가 아니라도 원칙적으로 문서소시자는 이를 제출할 의무가 있다. 예외 **(공증자)**:
공무원직무관련 문서
증언거부사유가 적힌 문서
[직업의 비밀·보호가치 판단] 判 **(공보/제공불실공)**
자기이용문서
[의의] 判 **(목내소/문목외/개불)**
[회사내부문서] 判**(열사동/외목/내자)** 사안**(합내목/회의개불)**
[2항 거부사유 증명책임] 신청자설/소지자설
3. 방식 (345)
4. 심리와 재판 (347)
[의견진술기회부여] 判 **(송의/존소서제)**
[필요하지 않은 경우] 判 (선결: 290)
5. 부제출 또는 사용방해의 효과
(1) 증명방해 의의 및 제제근거 **(고불/신)**
(ex 문서제출명령 불응도 증명방해의 일종)

(2) 요건 **(고알)**
i) 증거방법을 **고**의나 과실로 훼손
ii) 증명방해 결과가 됨을 **알**았거나 부주의로 알지 못했을 것
(3) 효과 자유심증설(判)/법정증거설/증명책임전환설/절충설
명문의 규정
349 (문서제출명령, 제시명령 따르지 않은 때) **(문주증/가편해)**
350 (문서 훼손하거나 사용할 수 없게 한 때) **(문주증/가편해)**
cf. 사용방해 목적 없이 훼손된 문서 제출 判 **(훼취불)**
369 (당사자가 정당한 사유 없이 출석하지 않거나
선서, 진술을 거부한 때) **(369주요/가편해)**
명문의 규정 無 **(증자전/가편해)**

IV. 검증 [녹음테이프 증거조사 방법] 서증설/검증설(判)
V. 당사자신문
1. 의의·법적성격 (367) **(당경증)**
2. 요건
(1) 다른 증거신청에 앞선 당사자신문 신청가부
(공/사신/367신진선) (증거방법으로서의 보충성)
(2) 유일한 증거여부
(3) 당사자신문 결과만으로 주요사실 인정가부
判 **(확당다/완)** (증거력으로서의 보충성)

VI. 증거보전
1. 의의 (375)
2. 요건 - 증거보전의 필요성

<자유심증주의>
1. 의의 (202)
법원은 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험칙에 따라 사실을 판단한다.
2. 내용
(1) 증거원인
1) 변론전체취지 [독립적증거원인] 보충적判/독립적 **(변사보/안)**
2) 증거조사결과 [증거공통원칙] 긍정判/부정 **(어제원어유/평자)**
(2) 심증형성정도
3. 예외
(1) 자백계약 可
(2) 증거제한 계약 可
1) 의의: 특정 증거방법 외 다른 증거방법은 쓰지 않기로 계약
2) 유효여부: 변론주의 범위 내 합의로서 적법·유효
3) 효력
증거제한계약 위반하여 증거신청한 경우, 상대방은 이를 채택하지 말라고 증거항변할 수 있고, 법원은 채택해서는 안 된다. 다만 증거조사가 종료된 경우, 자유심증의 영역으로 발전하여, 형성된 심증에 영향을 주어선 안 되므로 증거항변 할 수 없다.
(3) 증거력 계약 不可
(4) 증명책임 계약 可

<증명책임>
{기본 template}
1. 문제의 소재
2. 증명책임 의의 및 분배 **(요사/법주상)**
(1) 증명책임 의의 (2) 분배기준
(3) 소송요건
判例 본안판결 받는다는 것 자체가 원고에게 유리함에 비춰 직권조사사항인 소송요건에 대한 증명책임은 원고에게 있다.
(3) 소극적확인의 소
원고는 권리장애·멸각·저지규정에 해당하는 요건사실에 대한 증명책임을 지고, 피고는 권리근거규정에 해당하는 요건사실에 대한 증명책임을 진다.
3. 부당이득반환청구 법률상원인흠결에 대한 증명책임
(1) 학설 (2) 判例 1) 급부부당이득 2) 침해부당이득 (3) 검토
3. 무권대리 책임에 대한 증명책임
(1) 대리권수여사실, 추인사실 (민135①) **(원주무증)**
(2) 대리권 없음 알았거나 알 수 있었다는 사실 (135②) **(주증무)**

3. 등기의 추정력에 따른 증명책임 **(권다무법/신)**
(1) 문제점: 원인무효사실을 권리근거사실로 할지, 원인유효사실을 항변사실로 할지와 관련해 등기의 추정력의 성질이 문제
(2) 학설 법률상추정설(判)/사실상추정설 (3) 判例 (4) 검토

{취득시효 template} 이B 3회-1-2
1. 문제의 소재
2. 사안의 주요사실 (여유시 변론주의 일반론 추가)
i) 20년 점유, ii) 계속 점유 iii) 소유의 의사로 평온·공연 점유
3. 20년간 점유 인정여부
(1) 취득시효 기산점이 주요사실인지 **(법당/안)** (2) 사안
4. 점유계속사실 인정여부
(1) 민법 198조 추정
전후 양시 점유 사실이 있는 경우 계속된 점유로 추정한다.
법률상 추정에 의해 증명책임이 전환되므로 상대방이 점유중단사실에 대해(반대사실) 증명책임을 진다.
(2) 사안
5. 소유의 의사로 평온·공연 점유 인정여부
(1) 민법 197조 추정
점유자는 소유의 의사로 선의·평온·공연하게 점유한 것으로 추정한다. 잠정적 진실의 추정에 의해 증명책임이 전환되므로 상대방이 타주점유와 폭력·은비점유사실에 대해 증명책임을 진다.
(점유권원 주요사실인지 **(자당)**)
(2) 사안

{공해소송 template} 이C 3회-2
1. 문제의 소재
2. 증명책임 의의 및 분배
(1) 의의 **(요사)**
(2) 분배기준
1) 법률요건분류설 **(법주상)**
but 증거가 편재되어 있는 현대형소송에서 피해자에게 불리
2) 신설
i) 위험영역설: 손해원인이 가해자 위험영역에서 일어난 경우 가해자가 인과관계와 과실의 부존재 증명책임
ii) 증거거리설: 증거거리, 난이도를 고려해 분배
but 위험영역의 개념과 기준이 불명확, 증거거리 같은 경우 해결이 문제된다는 비판
3) 검토 - 수정법률요건분류설
입법자가 공평하게 본문과 단서를 구분해 놓았는바 원칙적으로 법률요건분류설이 타당. 다만, 증거편재를 시정하기 위해 현대형소송에서 증명책임 전환 또는 완화 타당.
3. 증명정도 완화로서 개연성이론 **(침손인상/반인)**
4. 일응추정과 간접반증이론
(1) 일응추정 의의: 고도의 개연성이 있는 경험칙을 이용한 추정
(2) 간접반증 의의·성질

추정의 간접사실과 양립하는 별개의 간접사실을 증명함으로써 주요사실의 추인을 방해하는 증명활동.
증명할 간접사실 자체는 법관에게 확신을 줄 정도로 증명해야 하므로 본증이지만, 주요사실에 대해서 반증이므로 증명책임 전환은 아니다.

(3) 공해소송 判例 (수도권매립지사건)
1) 인과관계 일응증명 **(배도손/배손인)**
2) 인과관계 부정 **(반원안/간손다)**

(4) 검토: 전체적으로 인과관계에 대한 개연성설을 토대로 한 간접반증이론을 취한 것으로 볼 수 있다.

(5) 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 판례 입장을 명문화하였다.

5. 사안해결

제4편【소송의 종료】
제1장 총설
제2장 당사자에 의한 종료 3개
<소취하>
[재소금지]
1. 재소금지 의의 (267②)
본안 종국판결 후에 소를 취하한 경우, 동일한 소를 제기할 수 없다. 소취하권 남용 및 종국판결농락 방지.
2. 재소금지 요건
1) 당사자동일 [변론종결 뒤 승계인]
[피대위자] 긍정설(判)/부정설 **(대피종피/담)**
[피보전채권 인낙한 채무자] 判 **(대적인채)**
2) 소송물 동일 [선결관계] 긍정설(判)/부정설 **(소전다동/다)**
(면직처분무효확인과 면직무효 전제로 부당이득반환청구)
(매매계약무효확인과 매매무효 전제로 매매대금반환청구)
3) 권리보호이익 동일
동일하지 않은 경우 判 **(재불허소)**
i) 피고가 소유권 침해를 중지해 소취하했는데 **재**침해
ii) 소취하 후 피고가 전소 취하 전제조건인 약정사항 **불**이행
iii) 토지거래허가 전에 소유권이전등기청구해 승소판결 받고 소취하했는데 그 뒤에 **허**가
iv) 소송요건 갖춰지지 않아 소취하했다가 이후 **소**송요건 갖춤
4) 본안의 종국판결 후 소 취하 [교환적 변경 법적성질]

<청구의 포기·인낙>
인낙 의의:
피고가 청구가 이유 있음을 인정하는 법원에 대한 일방적 의사표시

<재판상화해>
{제소전 or 소송상 화해 template}
1. 문제의 소재
2. 제소전 or 소송상 화해 법적성질 **(소순/220461)**
사법행위설/소송행위설(判)/양성설
3. 실체법상 하자 있는 경우 기판력 인정여부 **(재사화/준)**
무제한기판력설(判)/제한적기판력설/기판력 부정설
4. 기판력 저촉여부
(1) 주관적 범위
(2) 객관적 범위와 작용국면
1) 객관적 범위: 화해조항에 기판력이 생긴다
2) 작용국면: 후소 소송물이 화해조항의 법률관계와 동일하거나, 선결관계 또는 모순관계에 있어야 한다.
(3) 시적범위와 차단효
기판력은 화해성립시 권리관계 판단에 생긴다.
(화해 자체의 해제가 아니라, 화해로 인해 생긴 법률관계를 채무불이행 이유로 해제하면 차단되지 않음)
3. 화해 조건 가부 긍정설(判)/부정설 **(합이조/자)**

제3장 종국판결에 의한 종료 4개
{기판력 기본 template}
(다른 논점 있을시 기판력 저촉여부 목차 아래에 모으기
ex 중단간과판결, 화해권고결정, 조정)
1. 문제의 소재 2. 기판력 의의 **(구/안)**
3. 주관적 범위
4. 객관적 범위와 작용국면 (큰 논점 있으면 별개 중목차)
(1) 객관적 범위
확정판결은 주문에 포함된 것에 한해 기판력을 가진다.(216①)
사안에서 판결주문의 ~
(2) 작용국면
기판력이 작용하려면, 후소 소송물이 전소 소송물과 동일하거나, 선결관계 또는 모순관계에 있어야 한다.
5. 시적범위와 차단효
기판력은 사실심 변론종결시 권리관계 판단에 생긴다. 전소에서 확정된 권리관계와 다른 판단을 구하기 위해 전소 변론종결 전에 제출할 수 있었던 공격방어방법을 후소에서 제출할 수 없다.
(기판력 작용국면O) 변론종결 전 사유 OO은 차단된다.
(기판력 작용국면X) 변론종결 전 사유 OO도 차단되지 않는다.
6. 기판력 본질 (동일로 작용하는 경우에만)
모순금지설/반복금지설
cf. 선결관계: 후소 법원은 선결문제의 한도 내에서 전소의 기판력 있는 판단에 구속되어 이를 전제로 모순 없이 판단해야 한다.
cf. 모순관계: 모순금지설과 반복금지설 모두에서 소송물 동일과 같이 취급하여 후소를 각하해야 한다는 견해가 있지만, 소송물이 다르므로 후소 법원은 전소 판결을 전제로 하여 기각판결 해야 한다.

<기판력의 주관적 범위>
{변론종결 뒤 승계인 218① template}
1. 문제의 소재 2. 기판력 의의 **(구/안)**
3. 주관적 범위
(1) 상대성원칙과 확장
기판력은 당사자에게만 미치는 것이 원칙이나, 분쟁해결의 실효성을 위해 제3자에게 확장되는 경우가 있다. 丙이 218① 변론종결 뒤 승계인에 해당하는지 문제된다. **(뒤승고)**
(2) 변론종결 **뒤** 승계
"물권변동 효력이 생기는 소유권이전등기가 이루어진 시점을 기준으로 승계가 변론종결 후인지를 판단한다."
[채권승계] 判
[변종 전 승계인으로부터 변종 후 승계] 判 **(12변)**
(3) **승**계인의 범위
1) 소송물 승계인: 소송물 물권·채권 불문하고 승계인에 포함
2) 계쟁물 승계인 구이론(判)/신이론 **(채변변/양실)**
[물권적청구권 소송 원고측 계쟁물 승계인]判 **(소기/변패적패변)**
(4) **고**유의 방어방법 있는 경우 실질설(判)/형식설 **(명확매변/부)**
(통정허위표시 선의의 제3자, 동산 선의취득 주의!)
(5) 사안
[면책적 채무인수- 소송물 자체 승계O, 이B 2회-4-1
중첩적 채무인수- 별개의 채무 부담에 불과 승계인X]

목적물 소지자 요건
i) 당사자 또는 변론종결 뒤 승계인을 위해 소지하는 자
ii) 청구가 물권적·채권적인지, 목적물이 동산·부동산인지 불문
iii) 소지 시기는 변론종결 전후 불문하고, 자기의 고유한 이익을 위해 소지하는 임차인, 질권자는 해당하지 않는다.

{소송담당 218③ template}
1. 문제의 소재 2. 대위소송 법적성질 및 적법요건
3. 기판력 저촉여부
(1) 기판력 의의
(2) 주관적 범위-대위소송 기판력이 채무자에게 미치는지
1) 문제점 - 상대성원칙과 확장
2) 학설 3) 判例 3) 검토 4) 사안
(3) 객관적 범위와 작용국면 (4) 시적범위와 차단효
(5) 기판력 본질
4. 당사자적격 존부
(1) 피보전채권 존부 (or 보전의 필요성 여부) 判
(2) 사안
5. 결론 - 소송요건의 선순위성 원칙

c1.[대위소송 기판력이 채무자에게 미치는지]
적극설/절충설(判다수)/소극설
c2.[채무자의 확정판결 효력이 대위채권자에게 미치는지]
1 [채무자→제3채무자 소제기 패소확정後 대위소송 제기]
1) 기판력:기판력설/반사효설/법률요건적효력설 **(대판실효/채)**
2) 당사자적격 흠결: 채무자 권리불행사 X
2 [제3채무자→채무자 소제기 승소확정後 대위소송 제기]
1) 기판력 判 **(3소/이보/소3)**
2) 당사적격 흠결: 피보전채권 X **(기이피)** (이중매매, 조정)

c3.[대위소송 기판력이 다른 채권자에게 미치는지]
기판력설(判)/반사효설/부정설
c4.[대위소송 피보전채권無 소각하판결확정後 **(대소소피)**
채권자→채무자 피보전채권 이행소] 기 X (주관적범위X) 判
[대위소송 피보전채권無 소각하판결확정後
제3채무자→채권자 피보전채권 전제로 항변] 기O (선결문제)
c5.[채권자→채무자 피보전채권 이행소 패소확정後 대위소송 제기]
1) 기판력 (주관적범위X) 判
2) 당사자적격 흠결: 보전필요성 X 判 **(말동보부)**
[채권자→채무자 피보전채권 이행소 승소확정後 대위소송 제기]
1) 기판력 (주관적범위X) 判
2) 당사자적격 흠결: 判 **(보승3/발강확3피)**
기타의 효력, 기존/최근 (강행법규 위반시 피보전채권 X)

<기판력 객관적 범위와 작용국면>
I. 객관적 범위
[소송판결] 이B 5회-4
소송판결 주문에도 소가 부적법하다는 판단에 기판력이 생긴다.
"기판력은 각하이유로 된 소송요건에 관해서만 발생하고 다른 소송요건에 관해서는 발생하지 않는다."
[이유 중 판단] 소수설/통判
[동시이행항변] 判 **(존수조반이)**
[상계의 대상이 된 수동채권이 동시이행항변 채권] 判

[상계항변 template]
(1억 소제기 3억 상계항변 배척後 3억 소제기)
(1억 소제기 3억 상계항변 인용後 3억 소제기)
1. 문제의 소재 2. 기판력 의의 및 주관적 범위
3. 객관적 범위 - 상계항변 판단에 기판력 발생여부
(1) 기판력 인정과 취지
상계항변은 이유 중 판단이지만, 216조2항에 의해 예외적으로 기판력을 가진다. 기판력을 부정하면 상계항변 판단을 전제로 이루어진 원고 청구권에 대한 판결이 무의미하게 될 우려
(2) 기판력 발생요건 **(자수단)**
자동채권이 판단되고, **수**동채권이 소송물로서 심판되는 소구채권이거나 그와 실질적으로 동일하며, **단**독행위로서의 상계여야
(3) 기판력 발생범위
1) 상계항변 인정한 경우 **(대수대자)**
2) 상계항변 배척한 경우 **(존수대자)**
3) 복수의 상계항변 중 일부 배척한 경우 **(2존부부잔)**
(4) 사안: 1억 부존재 기판력 발생 / 1억 소멸 기판력 발생
4. 이유 중 판단 기판력 등 인정여부
5. 작용국면
사안은 전소판결에서 기판력이 발생한 자동채권과 동일한 채권을 후소 소송물로 했으므로 1억 한도 내에서 기판력이 작용
6. 기판력 본질 (시적범위 추가 可)
7. 사안해결
(1) 1억 부분: 청구기각 (패소한 자 동일한 소제기)
(2) 2억 부분: 기판력 X, but 증거효 때문에 기각
(1) 1억 부분: 소각하 (승소한 자 동일한 소제기)
(2) 2억 부분: 기판력 X, but 증거효 때문에 인용

II. 기판력 작용국면
작용국면 해당 O
1. 소송물 동일
[진명등 소이등]
1 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구 가부
긍정설(判)/부정설 **(표법말진/편경)**
2 진정명의회복 말소등기청구와 이전등기청구 소송물 동일여부
동일설(判)/별개설 **(목법동/방편)**
2. 선결관계
(1) 前 원본청구 後 이자청구 4-7-1A
(2) 前 소유권확인 後 소유권에 기한 인도청구
(3) 前 전세금반환청구패소 後 소유권에 기한 인도청구에서 전세금반환청구 있다고 하여 동시이행항변
(후소에서 문제되는 항변이 전소에 확정)
(4) 前 대표권 흠결 소각하 後 적법하게 대표자 선출해 ~청구
(후소에서 문제되는 소송요건이 전소에서 확정) 이B 5회-4
(5) 前 채무부존재확인 後 대여금 이행청구 4-3-2D
(小大관계에 있을 뿐이나 선결문제 준해 처리)
3. 모순관계
(1) 前 X소유권확인 後 Y소유권확인
(2) 前 말소등기청구 1.1매매무효 後 이전등기청구 1.1매매유효
cf. 前 말소등기청구 1.1매매무효 後 이전등기청구
전소 변종 전 9.1 매매유효 or 취득시효 4-3-3B
(다른 청구원인 사실을 문제 삼는 경우 모순관계아님)

작용국면 해당 X
[前특정부분 소이등 後지분 소이등] 判 **(취/공차/분/전불구)**
[前말소등기 後건물인도/부당이득] 判 **(소전말기)**
(이유 중 판단 기판력 논의)

[시효중단을 위한 재소] 이C8회-1-1
1. 문제의 소재 2. 기판력 의의
3. 승소확정판결 후 동일한 소제기시 소의 이익
(1) 원칙: 승소한자가 동일한 소를 제기한 경우 모순금지설은 소의 이익 없어 각하. 반복금지설은 기판력 자체로 각하
(2) 예외 - 시효중단을 위한 재소가부
1) 判例 다수의견 2) 判例 소수의견 3) 검토
4) 긍정할 경우 재소요건
4. 후소 법원의 본안심리방법
(1) 전소 변론종결 전 사유 차단 判 **(저확요)**
(2) 전소 변론종결 후 사유 제출 判 **(변소항인)**

[시효중단을 위한 새로운 방식의 확인소송] 이B 2회-3-2
(1) 判例 다수의견
1) 새로운 방식의 확인소송 허용 근거 **(시권권잠시)**
2) 종래 시효중단을 위한 이행소송의 문제점 **(이의조집적)**
3) 다수의견의 결론
(2) 判例 소수의견 **(변집시)** (3) 검토

<기판력 시적범위>
변종후 사유X
[변론종결 후 사유 의미] 判 **(새기다)**
[토지거래허가구역 해제] 判
① 변론종결 전 토지거래허가구역 해제 주장 **(토변알기)**
② 변론종결 후 토지거래허가 받은 사실 주장 **(변거결)**

변종후 사유O
[변론종결 후 변제하는 조건] 判 **(피회잔회기)**
[변론종결 후 조건성취] 判 [변론종결 후 이행가능] 判

[형성권, 한정승인 template]
1. 문제의 소재 2. 기판력 의의
3. 시적범위와 차단효
4. 변론종결 전 발생한 형성권 행사 가부 **(상청상적/임집임/안하)**
실권설/비실권설/상계권·매수청구권비실권설(判)/제한적실권설
4. 변론종결 전 한정승인사실 주장 가부
학설 **(책무기/책변청)** 判例 **(한책주기/변책한청)**
cf. [전소에서 한정승인 인정 후 후소에서 단순승인 주장] 判 **(한상변단책/상채)**

[임료상승 template]
1. 문제의 소재 - 기판력 의의
2. 추가청구 가부 **(일명기차/명)**
(1) 학설 시적한계설/별개소송물설/명시적일부청구의제설(判)
(2) 判例 (3) 검토 (2002개정법) (4) 사안
3. 변경의 소 가부
(1) 변경의 소 의의·성질 (252) **(액/형/형)**
(2) 변경의 소 요건·방식
i) 정기급 지급 명한 판결이 확정
ii) 액수산정의 기초가 된 사정이 현저히 바뀜
iii) 변경의 소 당사자적격 (기판력 받는 자) iv) 일반 소송요건 / 1심 법원의 전속관할
[확정판결 위법]判 **(뒤사종위)** [변종 뒤 승계인]判 **(소점채변)**
(3) 추가청구와의 관계
변경의 소로는 변경의 소제기 이후 증감액만 구제되기 때문에, 변경의 소 제기 전 부분에 대해 현저한 사정변경이 있는 경우 추가청구를 해야 한다.
(4) 사안

[후유증 or 기대여명 연장 template]
1. 문제의 소재 - 기판력 의의
2. 추가청구 가부 **(불새예포별/심)**
(1) 학설 시적한계설/별개소송물설(判)
(2) 判例 (3) 검토 (4) 사안 (부제소합의 위반 여부) 判
3. 변경의 소 가부
(1) 소송물동일설(多)/소송물별개설(호)
(2) 검토 (3) 사안

[화해권고결정 + 기대여명 단축 template]
1. 문제의 소재 - 기판력과 창설효
화해권고결정은 2주 내 이의신청 없는 때 재판상 화해와 동일효 (231), 재판상 화해는 확정판결과 동일한 효력이 있고 (220), "창설적 효력을 가지므로 종전 법률관계는 소멸함과 동시에 화해에 따른 새로운 법률관계가 형성된다"
2. 기판력의 의의
3. 주관적 범위
(1) 상대성 원칙과 확장 **(뒤승고)**
(2) 변론 종결 **뒤** 승계
"화해권고결정 송달 후에 생긴 사유에 대해서도 이의신청하여 새로운 주장을 할 수 있는 점에 비추어보면, 화해권고결정의 기판력은 그 확정시를 기준으로 발생한다."
(3) **승**계인 범위 (4) **고**유의 방어방법 있는 경우
(5) 사안: 상속인은 소송물을 포괄승계한 자로서 주관적 범위O
4. 객관적 범위와 작용국면
(1) 객관적 범위
(2) 작용국면 判 **(일재법기)** - 모순관계
5. 시적범위와 차단효: 사안에서 기대여명 단축은 확정 후 사유X

<판결의 편취>
{편취판결 template}
1. 문제의 소재 - 편취판결 의의
상대방이나 법원을 기망하여 부당한 내용의 판결을 받는 것
2. 편취판결의 효력: 무효설/유효설(判)
3. 소송법상 구제책: 항소설/추후보완·재심설
공시송달 **(공허송항)** 허위주소를 이용한 공시송달 451①11호
허위주소송달 **(허송송항)**
참칭대표자 **(참자송항)** 참칭대표자 451①3호
4. 실체법상 구제책
(1) 문제점: 편취판결에 의한 집행이 이루어진 경우, 편취판결을 재심으로 취소하지 않고 말소등기청구 등 가능한지 문제
(2) 학설 재심필요설(判)/재심불요설
(3) 判例 1) 말소등기청구의 경우 **(재기/기항별)**
2) 손해배상청구의 경우 **(기재/절재효정)**
(3) 검토 (4) 사안
5. 부당집행에 대한 구제책 - 청구이의의 소 **(부변집/의집/외)**
(1) 문제점: 편취판결의 집행단계에서 청구이의 소로 집행을 막을 수 있는지 문제. 이의원인이 변론종결 뒤 이유여야
(2) 긍정설(判)/부정설 (3) 判例 (4) 검토 (5) 사안

{공시송달 편취판결 + 재심보충성 template}
1. 문제의 소재
2. 편취판결의 효력 무효설/유효설(判)

3. 소송법상 구제책 항소설/추후보완·재심설(判) **(공허송항)**
4. 추후보완항소 가부
5. 재심 가부
   (1) 재심 의의·요건 (451①11)
      확정판결에 대한 비상의 불복수단. **(대기이사보)**
   (2) 재심기간 준수 여부 O 456①③
   (3) 재심의 보충성 위반 여부
      1) 보충성 의의 (451①단서)
         당사자가 상소에 의해 재심사유를 주장했거나 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 재심의 소를 제기할 수 없다.
         "알고도 주장하지 아니한 때란 상소하지 않은 경우까지도 포함한다"
      2) 判例 **(상독추재)** 3) 사안

일부판결 - 단순병합, 통상공동소송 可
상소불가분 예외 - 통공/ 불이익변경 예외 - 필공, 예공·선공, 독당
(상소불가분원칙 기본 내용)
상소불가분원칙에 의해 이심의 효력은 원칙적으로 상소인의 불복신청 범위와 관계없이 원판결 전부에 대해 불가분으로 발생한다
(객관적 병합에서 실질적으로 전부판결인 경우)
실질적으로 하나의 사건을 완결하는 전부판결이므로
상소불가분원칙이 적용되어 판단하지 않은 나머지 청구도 이심.

제5편【병합소송】
제1장 복수청구소송 4개
-----원시적병합-----
병합요건 - i) 동종절차 ii) 공통관할
[재심의 소에 통상의 민사청구 병합]

<청구의 병합 (객관적 병합)>
I. 단순병합 요건 i), ii) + iii) 관련성 不要
{단순병합 기본 template}
1. 문제의 소재
2. 甲청구병합의 형태
   (1) 단순병합 의의
      양립 가능한 여러 청구를 병렬적으로 병합하여 전부 심판을 구하는 형태의 병합이다.
      [관련성 없는 청구 선택적·예비적병합 청구] 判 **(논선보형)**
   (2) 사안
[관련적 단순병합 일부판결 적법여부] 判
3. 단순병합에서의 상소의 효력
   (1) 이심의 범위 -상소불가분의 원칙 적용 여부 소수설/통설(判)
   (2) 심판의 범위 - 불이익변경금지원칙 (415)
      1심판결은 그 불복의 한도 안에서만 바꿀 수 있다.
      상소심에서의 처분권주의의 발현이다.
   (3) 사안
4. 불복하지 않은 부분의 확정시기 (객관적병합) 통설/判例 **(변직)**

{대상청구 template}
1. 문제의 소재
2. 甲청구병합의 형태
   (1) 대상청구의 종류
      1) 이행불능 대비한 대상청구
      변론종결시 주청구의 이행불능을 대비해 전보배상을 청구하는 것으로서 주청구와 진정 예비적 병합이다. 특정물 청구에만可
      2) 집행불능 대비한 대상청구
      장래 집행단계에서 주청구의 집행불능을 대비해 전보배상을 미리 청구하는 것으로서 주청구와 단순병합이다.
      특정물은 물론 불특정물 청구에도 可 (현재이행+장래이행)
   (2) 집행불능 대비 대상청구 병합형태 判 **(본현이집단)**
   (3) 사안
3. 장래이행의 소 적법여부
   (1) 장래이행의 소 의의 (2) 소의 이익 (3) 사안
      대상청구의 기초인 매매계약이 변론종결시에 존재하고,
      집행불능이라는 조건 성취의 개연성/ 이전등기 거부함
4. 본안판단 적법여부
   (1) 대상청구의 심판방법 (집행불능 대비인 경우)
      주청구를 인용하는 경우 대상청구도 판단하여 별도의 주문을 내야 한다. (인용하는 경우가 많음) 주청구가 이유 없으면 대상청구는 심리할 것도 없이 배척한다.
   (2) 判例 **(예인생)** (3) 사안

II. 선택적병합 요건 i), ii) +
   iii) 양립할 수 있는 청구권·형성권 경합
   iv) 관련성

{선택적병합 판단누락 template}
   - case 1개: 청구기각, 어느 하나 판단 X
1. 문제의 소재
2. 甲청구병합의 형태
   (1) 선택적병합 의의
      양립 가능한 수개의 경합적 청구권에 기해 어느 한 청구의 인용을 해제조건으로 하여 다른 청구에 대해 심판을 구하는 형태의 병합이다.
   (2) 사안
(3. 일부인용시 다른 청구 판단요부 判 **(하불일판/경인)**)
4. 일부판결 가부 or 구제책 **(선항전판탈/하불)**
   판단누락설(判)/재판누락설

{선택적병합 청구인용 template}
1. 문제의 소재
2. 甲청구병합의 형태
3. 상소의 효력
   (1) 이심의 범위
      선택적병합에서 한 청구를 인용한 경우에 항소가 제기되면 실질적으로 하나의 사건을 완결하는 전부판결이므로 상소불가분원칙이 적용되어 판단하지 않은 나머지 청구도 이심.
      사안은~
   (2) 심판의 범위 및 순서 **(선인심/불순)**
      문제점 - 불이익변경금지원칙, 우선심판설/선택심판설(判)
4. 항소심판결 (원심과 다른 선택적청구 인용) **(결취새/소414)**
   항소기각설/항소인용설(判)
   cf. 순위를 붙인 경우 判 **(심주인예/결항새)**

III. 예비적병합 요건 i, ii) + iii) 양립불가능 iv) 관련성
[양적·질적 감축된 예비적 청구] 判 **(양동감흡)**
(ex 단순이행청구와 상환이행청구)

{예비적병합 판단누락}
   - case 2개: 1차 □ / 2차 먼저판결, 1차기각 / 2차 □
1. 문제의 소재
2. 甲 청구병합의 형태
   (1) 예비적병합 의의

양립 불가능한 여러 개 청구를 순차적으로 병합해 주위적 청구의 인용을 해제조건으로 예비적 청구에 관한 심판을 구하는 형태의 병합이다.
(2) 사안
3. 일부판결 가부 or 구제책 **(주배예/상누예판탈/하불)**
판단누락설(判)/재판누락설
4. 누락된 청구 별소제기 가부
(1) 기판력 저촉여부
판단누락설의 입장에서, 판결이 확정되었더라도 "어느 청구에 대해 법원이 전혀 판단하지 않았다면 그 부분은 기판력이 생길 수 없으므로" 후소가 기판력에 저촉되는 것은 아니다.
(2) 권리보호자격 여부 判 **(상오별권/분제)**

{예비적병합 1차 청구인용}
1. 문제의 소재
2. 甲 청구병합의 형태
3. 상소의 효력
(1) 이심의 범위
예비적병합에서 주위적 청구를 인용한 경우에 항소가 제기되면 실질적으로 하나의 사건을 완결하는 전부판결이므로 상소불가분원칙이 적용되어 판단하지 않은 나머지 청구도 이심. 사안은~
(2) 심판의 범위 判 **(주심예/주배예/불)**

{1차기각/2차인용에 대한 피고항소 template}
1. 문제의 소재
2. 甲 청구병합의 형태
3. 상소의 효력
(1) 이심의 범위
상소불가분원칙에 의해 이심의 효력은 원칙적으로 상소인의 불복신청 범위와 관계없이 원판결 전부에 대해 불가분으로 발생한다
(2) 심판의 범위 통설(判)/소수설 **(1이부심/방)**
4. 심판 대상이 되지 않은 주위적 청구에 대한 인낙 가부
判 **(1이인확종)**
cf. [예비적 청구에 대한 청구인낙 가부] 判 **(주예피효)**

{부진정예비적병합 - 대여금/불법손배 template}
1. 문제의 소재
2. 부진정예비적병합 의의
양립할 수 있는 청구임에도 불구하고 순서를 붙여 예비적 병합 형태로 청구하는 것
3. 부진정예비적병합 허용여부 긍정설(判)/부정설
4. 부진정예비적병합 요건
(1) 여러 청구의 논리적 관련성 → 단순병합 배척
"논리적으로 전혀 관계가 없어 순수하게 단순병합으로 구해야할 수 개 청구를 예비적 청구로 병합해 청구하는 것은 부적법"
(2) 심판순위를 붙여 청구할 합리적 필요성
"양 청구가 청구의 크기에 있어 차이가 있는 경우" 등
ex) 인정 예: 어음금/대여금, 전체/지분, 불법or채불/배상합의금
불인정 예: 대여금/불법손배
5. 甲 청구병합의 형태 **(형당성실/계불)**
선택적병합설(判)/부진정예비적병합설
6. 상소의 효력 判 **(실1피항/동구)**

{부진정예비적병합 일부인용 template}
1. 문제의 소재
2. 甲 청구병합의 형태
(1) 부진정예비적병합 의의
(2) 부진정예비적병합 허용여부
(3) 부진정예비적병합 요건
(4) 사안
3. 예비적 청구 판단요부와 석명의무
(1) 주위적 청구 일부인용시 예비적 청구 판단요부 判 **(주예의)**
(2) 법원의 석명의무 判 **(주예주예석)**
4. 부진정예비적병합에서 일부판결 가부
5. 사안해결
"석명의무를 위반한 나머지 예비적 청구에 관한 판단을 유탈한 잘못을 저질렀다."

-----후발적병합 = 관련청구 = 소송中의 소-----
병합요건 - 1), 2) + 3) 사실심 계속되고 변론종결 전
4) 구청구와의 관련성 + 5) 소송절차 현저히 지연X

<소변경> (262) (원고)
[청구취지 변경]
[청구취지확장] [청구취지감축]
[교환적 변경 법적성질]
[피고의 동의] [항소취하, 항소각하] 判 **(교심1대)** [재소금지]
[교환적 변경 후 구청구 심판] 判 **(소처종)**
[교환적 변경과 자백] 判 **(교대/배묵원예)**
[소변경 형태 불명확]
[석명 또는 지적의무] 判 소변경 형태가 불명할 경우 법원은 청구변경의 취지가 교환적인가 추가적인가에 대해 석명으로 밝힐 의무가 있다.
[신청구가 부적법한 경우 소변경 해석] 判 **(명부교종)**

{3억 소제기, 2억으로 감축, 2억2천 판결 template}
1. 문제의 소재 - 처분권주의 의의
2. 청구취지의 감축이 소의 일부취하인지여부 - 적극
(1) 문제점 청구취지를 감축하는 것은 소변경이 아니다. 다만, 일부포기인지, 일부취하인지 불분명한 경우 해석 문제
(2) 학설 다수설/소수설 (3) 判例 (4) 검토
3. 설문의 소의 일부취하가 유효한지 - 소극
(1) 소취하 요건 (266)
i) 판결이 확정되기까지
ii) 본안에 관해 응소한 경우 피고의 동의
(2) 사안 - 乙에게 송달하지 않은 바 乙의 동의 없음.
소취하 효력 없으므로 판결이 처분권주의 위반X
4. 취하서 제출시 법원의 처리 判 **(266송확결종)**
5. 결론: 법원이 취해야 할 절차를 위반한 위법이 있다.

{항소심에서 교환적변경 後 교환적변경, 추가적변경 template}
1. 문제의 소재
2. 전부승소한 OO 항소심에서 소변경 가부
(1) 부대항소 의의·취지 (403) **(피자/경)**
(2) 부대항소 성질 (배점고려)
(3) 부대항소 요건·방식
i) 주된 항소 적법하게 계속 중 ii) 주된 항소의 피항소인이 항소인을 상대로 iii) 항소심 변론종결 전 / 부대항소장 제출
(4) 사안 소변경신청서를 제출해도 "상대방에게 불리하게 되는 한도에서 부대항소를 한 취지로 볼 수 있다"
3. 소변경 적법여부 (특별소송요건)

(1) 소변경 의의 (262)
법원과 당사자의 동일성을 유지하며 소송물을 변경하는 것.
(2) 소변경 해당여부
소송물이론. ~ 다른 권리이므로 교환적변경 or 추가적변경
(3) 소변경 요건·방식
i) 동종절차 ii) 공통관할 iii) 사실심 변론종결 전
iv) 청구기초의 동일 v) 소송절차 현저히 지연시키지 않을 것
/ 청구취지 변경은 서면으로 신청
(4) 사안
(청구기초의 동일 포섭) 청구원인은 동일한데 청구취지만 변경 or 청구취지는 동일한데 청구원인만 변경 "동일한 사실 또는 경제적 이익에 관한 분쟁에 있어 해결 방법에 차이가 있을 뿐"
4. 교환적 변경 법적성질 - 구청구 취하여부
의의: 구청구에 "갈음하여" 신청구에 대해 심판을 구하는 소변경
독자제도설/결합설(判) **(신결심)**
5. 재소금지 저촉여부 (일반소송요건)
(1) 재소금지 의의 (267②)
본안 종국판결 후에 소를 취하한 경우, 동일한 소를 제기할 수 없다. 소취하권 남용 및 종국판결농락 방지.
(2) 재소금지 요건
i) 당사자 동일 ii) 소송물 동일 iii) 권리보호이익 동일
iv) 본안의 종국판결 후 소 취하
(3) 교환적 변경 후 재소금지 저촉여부
독자제도설/결합설(判) **(농재/본구종)**

{항소심에서 지분양도·소취하 後 추가적변경 template}
1. 문제의 소재
2. 전부승소한 OO 항소심에서 소변경 가부
3. 소변경의 적법여부 (+ 청구취지 확장이 소변경인지)
4. 재소금지 저촉여부
(1) 재소금지 의의 (2) 재소금지 요건
(3) 변론종결 뒤 승계인 재소금지 **(취양권/권기)**
특정승계인포함설(判)/불포함설
(4) 사안 **(지농취권권)**

<반소> (269) (피고)
[반소이익] 判 **(이채실)**
[채무부존재확인 본소와 이행청구의 반소] 判 **(소상소이/반본)**
[제3자 반소] 긍정설/제한적긍정설(判)/부정설 **(원3반/필68/규경)**
[본소 각하 후 반소 취하시 원고 동의 요부] 判 **(271반반강의)**
[점유권에 기한 본소에 소유권에 기한 반소]
1 반소 적법여부 **(208점본/청점본/별)**
2 집행문제 **(본점본반/실정장청)**
[반소 재판누락] 判 **(이주재/주재1상)**

{항소심 반소 template}
1. 문제의 소재
2. 전부승소한 OO 항소심에서 반소 가부
(1) 부대항소 의의·취지 (403)
(2) 부대항소 성질
(3) 부대항소 요건·방식
(4) 사안: 반소장을 제출해도 부대항소를 한 취지로 볼 수 있다.
3. 반소 적법여부 (특별소송요건)
(1) 반소 의의 (269)
소송계속 중 피고가 그 소송절차를 이용하여 원고에 대하여 제기하는 소. 소송경제
(2) 반소 요건·방식
i) 동종절차 ii) 공통관할 iii) 본소 사실심 변론종결 전
iv) 본소 청구 또는 방어방법과 관련성
v) 소송절차 현저히 지연시키지 않을 것 / 반소장 제출
(3) 본소 청구 or 방어방법과 관련성
[본소 청구와 관련성] **(취원대발주공)**
[본소 방어방법과 관련성] **(대발사법공/현허)**
(4) 항소심 반소 상대방 동의 요부
1) 상대방 동의 요부 (412①②)
2) 심급이익 해할 우려가 없는 반소 **(중원예심)**
i) **중**간확인의 반소 ii) 본소와 청구**원**인을 같이하는 반소
iii) 항소심에서 반소의 **예**비적 청구 추가
iv) 제1심에서 충분히 **심**리한 항변과 관련된 반소
4. 재소금지 or 중복소제기금지 저촉여부 (일반소송요건)

{판례사안 예비적 반소 template}
(1심 본소, 예비적 반소 모두 각하. 원고만 본소에 대해 항소.
2심 본소 청구인용, 예비적 반소 판단X.)
1. 문제의 소재
2. 1심 예비적 반소 각하 타당여부
(1) 예비적 반소의 의의 및 심판방법
본소청구의 인용을 대비하여 조건부로 제기하는 반소.
i) 본소가 각하·취하되면 반소는 소멸하고,
ii) 본소가 기각되면 반소는 판단할 필요가 없다.
(2) 사안 - 판단하여도 효력이 없다 (중대한 하자 무효)
3. 항소심 본소청구 인용가부
(1) 필수적환송과 예외적 자판 (418본문, 단서)
(2) 사안: 본소청구인용 부분은 부당한 점이 없다
3. 상소의 효력 - 예비적 반소 판단요부
(1) 이심의 범위
실질적으로 하나의 사건을 완결하는 전부판결이므로 상소불가분의 원칙이 적용되어 예비적 반소도 이심.
(2) 심판의 범위 **(예본예/무불)**

<중간확인의 소> (264)

제2장 다수당사자소송 4개
----- 원시적 병합 ----- 공유자/합유자/총유물
<공동소송> 연대채권자·연대채무자
불가분채권자·불가분채무자
공동소송 요건 동일사고 수인의 가해자·피해자
1. 주관적 요건 (65): 주채무자와 보증인
전문 - 권리나 의무가 공통 (공합총연불)
(관선수) - 사실상 또는 법률상 같은 원인 (동주)
후문 - 같은 종류 (수인의 임차인 보증금반환채권)
2. 객관적 요건 (253): 동종절차, 공통관할

I. 통상공동소송
template에서 심판방법은 뺄 수 있고, 넣더라도 양 조절 可
{통상공동소송 template}
1. 문제의 소재
2. 甲, 乙 공동소송 형태
(1) 구별기준
(2) 사안: 실체법상 관리처분권이 공동귀속되지 않고,
판결의 효력이 확장되는 관계가 아니므로, 통공 O

[매매예약완결권을 원인으로 한 가등기에 기한 본등기청구]
判 **(공지매/동의지피)**
3. 통상공동소송 심판방법 - 독립의 원칙 (66)
소송요건의 개별조사, 소송자료의 독립, 소송진행의 독립,
재판의 불통일 (일부판결可),
상소의 불통일 (합일확정 필요가 없으므로 상소불가분원칙 배제)
4. 독립의 원칙 수정여부
(1) 문제점: 65조 전문의 경우 판결의 모순은 부자연스럽다.
(2) 학설 (3) 判例 (4) 검토 **(66변행/66석)**

II. 필수적공동소송
1. 고유필수적 공동소송: 실체법상 관리처분권 공동귀속
(1) 합유관계: 합유물(민272), 합유지분(민273) 고필
다만, 보존행위(민272단서) 통공
(2) 총유관계: 총유물(민276) 고필
(3) 공유관계: 공유지분(민263),보존행위(민265단서) 대부분 통공
다만, 공유물(민264) 고필. 공유물 전체 소유권확인,
공유물분할청구, 경계확정청구
[소수지분권자 공유물 독점점유 다른 소수지분권자 상대 인도청구]
判 **(이보265지/공독/방)**
2. 유사필수적 공동소송: 소송법상 판결의 효력이 제3자에게 확장
수인 채권자의 대위소송

{고유필수적 공동소송 template}
1. 문제의 소재
2. 甲, 乙 공동소송의 형태
(1) 구별기준
(2) 사안
3. 고유(유사)필수적 공동소송 심판방법 - 연합관계 (67)
(1) 소송자료의 통일
1인의 소송행위는 모두의 이익을 위해서만 효력을 가진다. (67①)
(자백, 청구포기·인낙, 화해 무효. 일부소취하 유필에서만 유효)
상대방의 소송행위는 공동소송인 모두에게 효력이 미친다. (67②)
(2) 소송진행의 통일
1인의 중단사유는 모두에게 효력이 있고 (67③), 변론의 분리는
불가하다.
(3) 판결의 통일
합일확정 필요가 있으므로 일부판결은 불가하다.
(4) 상소의 통일
합일확정 필요가 있으므로 상소불가분원칙에 의해 1인 상소시
전원에 대해 판결 확정이 차단되고, 상소심으로 이심된다.
불이익변경금지원칙이 배제되어 상소하지 않은 자에게 유리하게
판결이 변경될 수 있다.
(5) 상소하지 않은 자의 지위
상소인설, 선정자설이 있으나,
判例는 합일확정의 필요에서 어쩔 수 없이 상소심에 관여하는
지위에 있다는 상소심당사자설 입장이다.

4. 丙 누락한 경우 소의 적법여부
(1) 고유필수적 공동소송 당사자적격
고유필수적 공동소송은 공동소송이 강제되므로, 공동소송인
중 일부가 누락된 경우 당사자자적격 흠결로 소는 부적법하다
다만, 변론종결시까지 누락 당사자를 보정할 수 있다.
(2) 사안
5. 별소제기와 법원의 변론병합
6. 원고의 고유필수적 공동소송인 추가
(1) 의의 (68) (2) 요건 (3) 사안
7. 누락자의 공동소송참가
(1) 의의 (83) (2) 요건
(3) 고유필수적 공동소송에서 공동소송참가 가부
긍정설(多)/부정설
(4) 사안

4. 丙 끌어들이지 않은 경우 소의 적법여부
(1) 고유필수적공동소송 당사자적격
(2) 判例 [공유물분할청구 소송 중 공유지분 양도] **(공변일부)**
(3) 사안
5. 인수승계 가부
(1) 인수승계 의의·요건 (2) 승계인의 범위
(3) 사안 계쟁물인 토지지분을 승계했고, 그 승계로 인해 공유물
분할의무 승계하므로, '소송목적인 의무를 승계'한 자에 해당
6. 인수승계 절차
(1) 인수승계 형태 (2) 추가적 인수 가부

4. 乙 제소 전 사망시 소의 적법여부
(1) 判例 [공유물분할청구 1인의 제소 전 사망] **(공합흠부)**
(2) 사안
5. 보정방법 - 당사자확정, 표시정정

III. 예비적·선택적공동소송 (70)
{예비적 공동소송 template}
1. 문제의 소재
2. 예비적 공동소송 적법여부
(1) 예비적 공동소송 의의 (70)
(2) 예비적 공동소송 허용여부
예비적 피고의 불안한 지위를 이유로 불허설이 있었으나,
개정법은 모든 공동소송인에 관한 청구에 대해 판결해야한다고
규정해 이를 해결하고 (70②), 소송경제와 재판통일을 위해 허용
(3) 예비적 공동소송 요건
1) 법률상 양립불가능
판단방법 判 **(법택반판)**
[원고 청구병합시] 判
[소송법상 양립불가능] 判 **(실개피어법)**
2) 공동소송 요건 (65, 253)
O i) 공탁 무효임을 전제로 보험금 청구, 공탁 유효임을 전제로
공탁금출급청구 승낙의사표시
ii) 제3채무자에게 통정허위표시 말소등기청구, 채무자에게
허위표시가 아니면 전보배상청구
iii) 명의신탁약정 유효 전제로 신탁해지 원인으로 소이등청구,
약정 무효 전제로 매매 원인으로 소이등청구
iv) 은행간부와 은행에 대해 퇴직금청구는 하나의 고용계약에
기초한 것으로서 피고들에 대한 청구가 양립할 수 없다.
X i) 수자원공사와 국가 부당이득반환채무 부진정연대

3. 예비적 공동소송 심판방법 - 67조 준용
(1) 소송자료의 통일
1인의 소송행위는 모두의 이익을 위해서만 효력을 가진다. (67①)
다만, 소취하, 청구포기·인낙, 화해 각자 할 수 있다. (70①단서)
상대방의 소송행위는 공동소송인 모두에게 효력이 미친다. (67②)
(2) 소송진행의 통일
1인의 중단사유는 모두에게 효력이 있고 (67③), 변론의 분리는
불가하다.

(3) 재판의 통일 判 **(일흠상누판)**
(4) 상소의 통일
1) 상소불가분원칙 적용, 불이익변경금지원칙 배제
합일확정 필요가 있으므로, "주위적 공동소송인과 예비적 공동소송인 중 어느 한 사람이 상소를 제기하면 다른 공동소송인에 관한 청구 부분도 확정이 차단되고 상소심에 이심되어 심판대상"
2) 주위적 피고에 대한 소취하시 심판범위 判
(5) 상소하지 않은 자의 지위
(공동소송에서 상소 문제 나오면 위와 같이 심판방법까지 같이 써주는 것이 득점에 유리할 것으로 생각. 다만, 독당참은 상소 파트 논의가 풍부하므로 객관적 병합 template로 쓰는 게 좋아보임)

[예비적 피고 인낙·화해] 허용설(多)/불허설
[1인의 자백] 긍정설/부정설
[조정·화해권고결정(231)의 효력]
1) 원칙 判 **(재이확)** 2) 예외 判 **(분공통)**
3) 학설 - 비판적 견해 4) 검토 **(재상)**

IV. 추가적공동소송
[규정에 없는 주관적 추가적 병합 가부] (통공추가) **(표필/해)**

<선정당사자>
{선정당사자 template}
1. 문제의 소재
2. 선정당사자 선정의 적법 여부
(1) 선정당사자 의의
공동의이해관계 있는 다수당사자가 소송할 경우, 총원을 위해 소송 수행할 당사자로 선출된 자. 다수당사자 소송의 단순화.
(2) 선정 요건·방식
i) 공동소송을 할 여러 사람, ii) 공동의 이해관계
iii) 공동의 이해관계인 중 선정 /
선정은 각 선정자가 개별적으로 해야 하며, 다수결로 不可
(3) 공동의 이해관계 인정범위 (65조 전문 +65조 후문 쟁점공통)
1) 학설 2) 判例 공동이해관계 의미 **(공주권발)**
3) 검토 65조 후문의 경우 **(임쟁주)**
(4) 사안
3. 항소심에서의 선정당사자 자격
(1) 심급을 제한한 선정 가부 **(총장심/강)**
1) 학설 소송종료설/심급한정설(判)
2) 判例 3) 검토
(2) '1심 소송절차에 관하여'가 심급제한인지 判例/검토

[선정당사자 지위]
(1) 당사자 본인으로서의 지위 判 **(일개)**
(2) 같은 선정자단에서 선정된 여러 선정당사자 지위
소송수행권을 합유하는 관계이므로 고유필수적 공동소송
(3) 별개 선정자단에서 선정된 여러 선정당사자 지위
원래 여러 사람의 공동소송이 통상공동소송이라면, 통상공동소송
(4) 선정당사자 자격상실
1) 자격상실 사유
선정의 취소, 선정당사자의 사망, 선정당사자 본인 부분 소가 취하되거나 판결이 확정되어 공동이해관계가 소멸되는 경우
2) 상대방에 대한 통지 (63②)
[묵시적 선정철회의사표시] 判 **(명자항묵)**
3) 절차중단 54, 237②
[선정자 지위] 적격유지설/적격상실설(判)

----- 후발적 병합 -----
<참가>
I. 보조참가 (71) - 판결효력 X
{보조참가 template} 이C5회-3, 곽B 7회-1-3
1. 문제의 소재
2. 보조참가 적법 여부
(1) 보조참가 의의 (71)
소송결과에 이해관계가 있는 자가 소송에 참가하는 것으로 피참가인의 불이익 방지하고 참가인에게 참가적 효력을 미치기 위함.
(2) 보조참가 요건
i) 타인 소송 계속 중 ii) 참가이유 - 소송결과에 이해관계
iii) 소송절차 현저히 지연시키지 않을 것 iv) 소송행위 유효요건
(3) '소송'에 대한 이해관계
1) 다수설判例: 판결주문에서 판단되는 소송물의 권리관계의 존부에 의해 보조참가인의 법률상 지위가 결정되는 관계에 있을 때에 한해 참가이익이 있다.
2) 소수설: 이유에서 판단되는 쟁점에 의해 참가인의 지위가 결정되는 관계일 때도 참가 가능
3) 검토: 소수설 판결이유 중 판단 기판력 인정할 수 없는 점, 보조참가의 범위가 넓어진다는 점에서 부당
(4) '결과'에 대한 '이해관계'
피참가인이 패소하면 그로부터 구상청구를 당하는 등 불리한 영향을 받아야 한다. 법률상 이해관계여야 하고 사실상·경제상 이해관계로는 부족하다.
(5) 사안
O i) 채권자→보증인 채무이행청구, 주채무자 보증인에게 참가
ii) 제3자→매수인 인도청구, 매도인 매수인에게 참가
iii) 피해자→가해자 손해배상청구, 보험회사 가해자에게 참가
X i) 공동피해자 중 1인이 다른 피해자의 소송에 참가
ii) 공동불법행위자 중 1인이 피해자의 소송에 참가 (判 인정)
iii) 부양의무를 부담할 친족, 회사재산 감소로 이익배당이 줄어드는 주주, 채무자의 책임재산이 감소해 변제받기 어려워지는 일반채권자 (반대 견해 有)

3. 보조참가인의 지위
(1) 독립적 지위
참가인은 자기의 이익을 옹호하기 위해 당사자에 준하는 절차관여권 인정. [기일통지] 判
공격·방어·이의·상소 등 모든 소송행위 (76①본문)
(2) 종속적 지위
참가인은 피참가인의 승소를 보조하는 자일뿐 당사자는 아니므로, 그 지위는 피참가인에게 종속한다. **(할어불확사)**
i) 소송정도에 따라 피참가인이 **할** 수 없는 행위 (76①단),
ii) 피참가인의 행위와 **어**긋나는 행위 (76②),
iii) 피참가인에게 **불**이익한 행위, iv) 심판대상 변경·**확**장하는 행위
v) 피참가인의 **사**법상 권리행사 (명문의 규정이 없는 경우)
[피참가인의 행위와 어긋날 경우의 의미] 判 **(적소명자적)**
4. 보조참가인의 상소기간
다수설(判)/소수설 **(할피부/당)**

{참가적 효력 template}
1. 문제의 소재
2. 참가효 의의·성질 (77)
재판은 참가인에게도 효력이 미친다. 이는 **(공형패)**
3. 주관적 범위
통설·判例인 참가적 효력설은 "77조는 참가인이 피참가인에게

패소판결이 부당하다고 주장할 수 없게 하는 참가적 효력"만을 규정하므로 참가효는 참가인과 피참가인 사이에만 미친다고 한다.

4. 객관적 범위
판결주문 및 판결이유 중 판단. "참가인과 피참가인이 공동이익으로 주장하거나 다툴 수 있었던 사항에 한하여."
(ex 도급계약이 있었는지는 이해가 대립되는 사항)
[화해권고결정] 判 **(화법참)**

5. 배제사유 (77 각호) **(할어방고)**
i) 참가인이 소송행위를 **할** 수 없거나,
ii) 피참가인의 행위와 **어**긋나 효력을 갖지 않은 때,
iii) 피참가인이 참가인의 소송행위를 **방**해한 때, iv) 피참가인이 참가인이 할 수 없는 소송행위를 **고**의나 과실로 하지 않은 때

[참가효의 주관적 범위] (참가인과 피참가인의 상대방 사이 논점)
참가적 효력설(判)/신기판력설

II. 공동소송적 보조참가 (78) - 판결효력 O
i) 타인 소송계속 중 ii) 판결의 효력 미치는 경우 iii) 일반소송요건X
유사필수적 공동소송인 준하는 지위 (67 준용)
ex) 대위소송 중 채무자 참가, 선정당사자 소송 중 선정자 참가
파산관재인의 파산재단 소송 중 파산자 참가

III. 공동소송참가 (83) - 판결효력 O
i) 타인 소송계속 중 ii) 소송목적 합일확정 필요 iii) 일반소송요건
필수적 공동소송인 (당사자)이 된다 (67 적용)
ex) 대위소송 중 다른 채권자 참가, 주주의 대표소송 중 회사 참가

{대위소송 중 채무자 참가 template}
1. 문제의 소재
2. 대위소송의 법적성질
3. 채무자의 참가 형태 **(합적중/적중/기/경모적)**
공동소송적 보조참가설(判)/공동소송참가설/보조참가설
4. 공동소송적 보조참가인의 지위
(1) 유사필수적 공동소송에 준하는 지위
공동소송적 보조참가인은 판결의 효력을 받으므로 보조참가인에 비해 독립성이 강하다. 유사필수적 공동소송에 준한다.
(2) 보조참가와의 차이점
i) 피참가인의 행위와 어긋나는 행위 (67①)
ii) 참가인 소송절차 중단·중지사유 발생시 소송절차 정지 (67③)
iii) 참가인의 상소기간 독립적으로 계산
(3) 보조참가와의 공통점
이 밖에 보조참가인과 동일한 지위. 소송정도에 따라 피참가인 할 수 없는 행위를 할 수 없다.
4. 피참가인의 지위
(1) 유사필수적 공동소송에 준하는 지위
공동소송적 보조참가에는 필수적 공동소송에 관한 67조 1항이 준용되므로 피참가인의 소송행위는 모두의 이익을 위해서만 효력을 가지고, 공동소송적 보조참가인에게 불이익한 행위는 효력이 없다. (判例)
(2) 피참가인이 할 수 없는 행위
자백이나 청구포기·인낙, 화해, 상고취하, 상고권포기, 재심의 소취하와 같이 재판의 효력과 관련이 있는 행위는 참가인에게 효력이 없다. 재심의 소취하 判 **(배효불취)**
(3) 피참가인이 할 수 있는 행위 - 소취하 判 **(유취/효불취)**

{대위소송 중 다른 채권자 참가 template}
(참가 후 대위채권자끼리 유사필수적 공동소송 67조 적용)
1. 문제의 소재
2. 대위소송의 법적성질
3. 乙의 공동소송참가 적법여부
(1) 공동소송참가 의의·요건
i) 타인 소송계속 중 ii) 소송목적 합일확정 필요 iii) 일반소송요건
(2) 소송목적 합일확정 필요여부 **(대동83적/피이대/명초동)**
1) 학설 법정소송담당설/고유의 대위권설
2) 判例
① 채권자들의 대위소송의 경우 합일확정 요부
② 채권자들이 자신을 이행상대방으로 한 경우 합일확정 요부
③ 일부청구임을 명시한 대위소송의 경우 합일확정 요부
3) 검토
(3) 일반소송요건 구비여부
1) 당사자적격 여부
채권자의 권리행사시 민법 405②에 의해 채무자는 당사자적격 상실O, 다른 채권자는 당사자적격 상실X
2) 중복소제기 여부
별소 제기 하는 것이 아니라 이미 계속된 소송에 참가하는 것은 판결의 모순 위험도 없으므로 중복소제기 해당X

IV. 소송고지 (84) {소송고지 template}
1. 문제의 소재
2. 소송고지 적법여부
(1) 소송고지 의의 (84)
소송이 계속된 때 당사자가 참가할 수 있는 제3자에게 소송계속 사실을 통지하는 것. 제3자에게 자기이익 옹호할 기회를 주고 참가적 효력을 미치기 위함.
(2) 요건·방식
i) 소송계속 중 ii) 고지자가 원고·피고, 보조참가인 및 이들로부터 고지받은 자 iii) 피고지자가 소송에 참가할 수 있는 자
/ 이유와 소송진행 정도를 적은 서면을 법원에 제출하면, 피고지자와 상대방에게 송달한다. (85)
(3) 사안
3. 소송고지의 효과 - 참가적 효력
(1) 참가효 의의 (86)
(2) 주관적 범위: 피고지자와 고지자 사이에 미친다
(3) 객관적 범위
판결주문 및 판결이유 중 판단. "피고지자가 고지자와 공동이익으로 주장하거나 다툴 수 있었던 사항에 한하여."
(4) 배제사유
참가효의 배제법리가 적용된다. "고지자가 소송에서 항변을 하지 아니하여 고지자에게 패소판결을 했다면 피고지자는 판결결과에 구속받지 않는다"
(5) 사안

V. 독립당사자참가 (79) - 판결효력 X
{독립당사자참가 template}
1. 문제의 소재
2. 독립당사자참가 적법 여부
(1) 독립당사자 참가 의의 **(권침당/분)**
(2) 요건
i) 타인 소송계속 중 ii) 참가이유 iii) 참가취지
iv) 소의 병합요건- 동종절차, 공통관할 v) 일반소송요건

(3) 권리주장참가의 참가이유
1) 판단기준
"원고의 본소청구와 참가인의 청구가 주장 자체에서 양립할 수 없는 관계인 경우 허용된다." 서로 자신이 물권자 또는 채권자라고 주장하는 경우가 있다.
[원고의 청구 병합된 경우]
判例 본소에 청구가 병합된 경우 한 청구라도 참가인의 주장과 양립하지 않으면 본소청구에 대한 참가가 허용된다.
[본소청구 이유 없는 경우]
判例 양립할 수 없는 본소청구에 관하여 본안심리한 결과 이유가 없는 것으로 판단되더라도 참가신청이 부적법하게 되는 것은 아니다.
[이중매매] **(주소양부/주)** 적법설/부적법설(判)
(3) 사해방지참가의 참가이유 - 소송결과에 따라 권리침해 의미
판결효설/이해관계설/사해의사설(判)
(4) 참가취지 - 편면참가 가부
1) 종래 判例
편면참가를 불허했고, 쌍면참가한 경우에도
원고에게는 원고의 피고에 대한 청구기각만 구한 경우, 일방 청구에 소의 이익이 없거나, 주장자체로 이유 없는 경우 불허
2) 개정법: 참가의 활성화를 위해 편면참가 허용
(5) 일반소송요건 구비 여부
[참칭채권자에 대한 청구권확인] 判 **(채변침즉장)**
[상대방의 청구권부존재확인] 判 **(독원/참원/원3)**
[제3자 권리관계 확인의 이익]
判例 제3자 권리관계와 관련하여 **(법현장)**
[채권자취소소송 사해방지참가 소의 이익] 判 **(사원법/독법목)**

3. 독립당사자참가에서의 상소의 효력
(1) 이심의 범위 분리확정설/이심설(判) **(독차이/합)**
(2) 상소하지 않은 자의 지위
상소인설, 피상소인설, 승소자에게는 상소인 패소자에게는 피상소인이 된다는 이중지위겸유설이 있으나,
判例는 합일확정의 필요에서 어쩔 수 없이 상소심에 관여하는 지위에 있다는 상소심당사자설 입장이다.
(3) 심판의 범위 **(합항유/각항항)**
1) 불이익 변경금지 원칙
2) 합일확정이 필요한 경우 - 원칙 배제
3) 합일확정이 필요 없는 경우 - 원칙 적용

[일부화해] **(불효재합/이효소)** (선결: 독립당사자참가 심판방법)

<당사자 변경>
I. 임의적 당사자변경
1. 규정이 없는 임의적 당사자변경
2. 피고경정 (260)
(1) 요건
i) 피고를 잘못 지정한 것이 분명
ii) 1심 변론종결시까지 iii) 피고의 동의 iv) 소송물 동일
(2) 절차와 심판
(3) 효과
i) 시효중단 효과는 경정시 발생
ii) 종전 당사자 소송수행 결과 불승계 원칙
3. 고유필수적 공동소송인 추가 (68)
(1) 요건
i) 고유필수적 공동소송인 중 일부 누락
ii) 1심 변론종결시까지 iii) 원고 추가시 추가될 사람 동의
iv) 공동소송요건
(2) 절차와 심판
(3) 효과
i) 시효중단 효과는 제소시에 소급
ii) 종전 공동소송인 소송수행 결과 유리한 것만 승계
4. 예비적·선택적 공동소송인 추가 (70) - 68조 준용

II. 소송승계
1. 당연승계
[수계 후 승계인(진정상속인) 아님이 밝혀진 경우 조치]
소각하설/수계신청각하설/수계신청기각설(判) **(1파기환/간243)**
[참칭상속인에 대한 판결의 효력] 判 **(청중기)**
cf. [인수신청 후 승계인 아님이 밝혀진 경우 조치]
소각하설/인수신청각하설/청구기각설(判) **(명청청인/적실분)**
2. 특정승계
참가승계
(1) 요건
(2) 절차와 심판
1) 승계사실 다툼이 없는 경우 (편면참가)
전주 탈퇴 O (원칙)… 전주와 승계인 소송형태 논의X
전주 탈퇴 X … 종래 통공, 전합 67준용
2) 승계사실 다툼이 있는 경우 (쌍면참가)
전주 탈퇴 X … 독당, 즉 67준용
(3) 효과
i) 시효중단 효과는 제소시에 소급
ii) 종전 당사자의 소송수행 결과 유·불리 불문 승계
인수승계
(1) 요건
(2) 절차와 심판
1) 교환적 인수
전주 탈퇴 O … 전주와 승계인 소송형태 논의X
2) 추가적 인수
전주 탈퇴 X … 판단기준 따라 통공 or 필공
(3) 효과 동일

{참가승계 template}
1. 문제의 소재
2. 참가승계 가부
(1) 참가승계의 의의·요건 (81)
i) 타인 소송 계속 중 ii) 소송목적인 권리의무의 승계
(2) 승계인의 범위
1) 소송물 승계인: 소송물 물권·채권 불문하고 승계인에 포함
2) 계쟁물 승계인: 구이론(判)/신이론
(3) 사안 - 참가승계 可
3. 참가승계 절차
독립당사자참가신청 방식에 의한다. 전주와 승계인 간에 다툼이 없는 경우, 참가인이 전주에게 청구를 하지 않고 편면참가한다. 다툼이 있는 경우, 전주에게도 일정한 청구를 하여 쌍면참가한다.
4. 甲(전주)과 丙(승계인)의 지위
(1) 승계 전 甲의 행위가 丙에게 영향 있는지
소송수행의 결과를 유리·불리 불문하고 그대로 승계한다
(2) 승계 후 甲과 丙의 소송형태 (전주가 탈퇴하지 않는다면)
1) 승계사실 다툼이 있는 경우 - 독당, 즉 67 준용
2) 승계사실 다툼이 없는 경우 - 67 준용

{참가승계 소송형태 template}
1. 문제의 소재
2. 승계 후 甲(전주)와 丙(승계인)의 소송형태
(1) 승계사실 다툼이 있는 경우
누가 권리자인지 다투어지면 "원고, 피고, 승계참가인 사이에 삼면소송관계가 성립되므로 법원은 독립당사자참가에 준해 심리"
(2) 승계사실 다툼이 없는 경우 **(독통/승인주필합/필양필)**
1) 문제점: "원고가 승계를 다투지 않으면서도 소송탈퇴, 소취하를 하지 않거나 이에 대해 피고가 부동의해 원고가 소송에 남는 경우" 전주와 승계인의 소송형태가 문제된다.
2) 학설
3) 判例 ① 종래 판례 ② 전원합의체 판례
4) 검토
3. 필수적 공동소송 심판방법
4. 사안해결

{인수승계 template}
1. 문제의 소재
2. 인수승계 가부
(1) 인수승계의 의의·요건 (82)
i) 타인 소송계속 중 ii) 소송목적인 권리의무의 승계
(2) 승계인의 범위
1) 소송물 승계인: 소송물 물권·채권 불문하고 승계인에 포함
2) 계쟁물 승계인: 구이론(判)/신이론
(3) 사안 - 인수승계 可
3. 인수승계 절차
(1) 인수승계 형태: 교환적 인수는 소송목적인 채무를 제3자가 승계하여 적격자가 바뀌는 경우에 한다. 추가적 인수는 분쟁이 확대되어 제3자가 새 채무자로서 적격자가 추가되는 경우에 한다.
(2) 추가적 인수 가부 **(건말공)** (3) 사안
4. 乙(전주)과 丙(승계인)의 지위
(1) 승계 전 乙의 행위가 丙에게 영향 있는지
소송수행의 결과를 유리·불리 불문하고 그대로 승계한다
(2) 승계 후 乙과 丙의 소송형태 (추가적 인수라면)
1) 공동소송 형태 2) 심판방법 3) 독립의 원칙 수정여부

{시효중단 template}
(인수 후 탈퇴한 원고가 인수인에 대한 판결 확정 6개월내 청구)
1. 문제의 소재
2. 인수승계와 시효중단 시기
(1) 민사소송법 265, 82③준용 81
소제기시 또는 소변경시 시효중단의 효력이 있다.
"인수결정하면 소송이 처음 계속된 때 소급해 시효중단 효력"
(2) 사안:
甲의 18.11.1 소제기로 시효중단 (265), 丙의 인수승계 이후 소송이 처음 계속된 때 소급해 시효중단 효력 (82③준용 81)
3. 시효중단 효력 소멸
(1) 민법 170①
재판상 청구는 각하, 기각, 취하된 경우 시효중단 효력이 없다
(2) 사안:
丙 소각하(청구기각) 판결 확정 후 시효중단 효력 소멸 (170①)
4. 탈퇴원고 甲의 청구로 시효중단 효력 유지여부
(1) 민법 170②, 민사소송법 82③준용 80단서
170조 1항의 경우 6월 내 재판상 청구를 하면 시효는 최초의 재판상 청구로 중단된 것으로 본다.
"탈퇴 후 잔존 소송에서 내린 판결은 탈퇴자에게도 효력이 미치는 점에 비추어 보면" 탈퇴자가 6개월 내에 재판상 청구한 경우에도 같다.
(2) 判例 **(소인6재재유)**
(3) 사안

제6편【상소심절차】

제1장 총설

I. 상소요건 (대기이포불신중)
대상적격, **기**간준수, 상소**이**익, 상소**포**기 또는 **불**상소합의가 없을 것, 기타 소송행위 요건(**신**의칙 위반 되지 않을 것, **중**단 중의 상소가 아닐 것)
1. 대상적격: 선고+종국+유효
2. 기간준수: 판결정본 송달 후 2주 (송달 전에도 可, 396)
3. 상소이익
(1) 의의·취지: 하급심판결의 취소, 변경을 구할 수 있는 이익.
남상소 방지를 위한 상소요건
(2) 판단기준 형식적불복설(判)/실질적불복설/절충설/신실질적불복설
[전부 승소한 자]
[묵시적 일부청구] 判 **(잔기전나) (단편실항)**
[상계항변] **(상소기)** → 항소심에서 상계가 아닌 피고의 다른 주장에 의해 청구기각하려면 1심판결 취소하고 판결이유를 바꾸어 청구기각판결 한다. (414조에 따라 항소기각X)
[청구권 경합] 判 **(주원청불)**
[대위소송 피보전채권] 判 **(기승피)**

II. 상소의 효력
상소불가분의 원칙 (전부이심)
1. 객관적병합 예외 無
2. 주관적병합 1) 통공: 상불원 예외 (일부이심)
2) 필공, 예공·선공, 독당: (전부이심)
불변금 예외 (전부심판)

제2장 항소

<항소 제기와 취하, 부대항소>
I. 항소제기
[항소장부본 송달불능] 判 **(402항주각문최수/소불/주공)**
II. 항소취하
1. 의의 (393①)
항소인이 1심 판결에 대한 불복신청을 철회하는 것
2. 관련문제
[항소취하 후 재항소] 判 **(후만확/전내다)**
[항소의 일부취하] 判 **(전일효/일불변효)**
[파기환송 후 항소취하] 判 **(파항종부/부은)** (→404조 논점)
III. 부대항소
1. 의의·취지 (403) **(피자/경)**
2. 성질 항소설/비항소설(判)
3. 요건·방식
i) 주된 항소 적법하게 계속 중 ii) 주된 항소의 피항소인이 항소인을 상대로 iii) 항소심 변론종결 전 / 부대항소장 제출
4. 효력
(1) 항소심 심판범위 확장 - 불변금 배제
(2) 부대항소의 종속성 (404)

<항소심 심리>
I. 항소의 적법성 심리
II. 항소의 이유구비성 심리 (본안심리)
항소취지는 항소제기시에 확정되어야 하는 것은 아니고 항소심 변론종결시까지 변경할 수 있다.

<항소심 종국적 재판>
1심판결 정당-항소기각 (414①②)
1심판결 부당-항소인용-1심판결취소(416)-자판원칙/ 환송예외(418)
불이익변경금지의 원칙 (415)
1. 의의
1심판결은 그 불복의 한도 안에서만 바꿀 수 있다.
상소심에서의 처분권주의의 발현이다.
2. 내용
[소각하판결]
항소기각설(判)/환송설/청구기각설(多) **(각심청항/잘경)**
[상계항변 인용판결]
1 판단기준
원심판결 주문과 상급심판결 주문 형식적으로 비교하여 판단한다. 판결이유 중 상계항변 판단은 216조2항에 따라 기판력 발생하여 그 내용이 불이익하게 변경되는 것도 동 원칙 위배
2 상계항변 인용판결에 대해 원고만이 항소한 경우 判 **(소청불)** (자동채권 부존재를 이유로 항소)
3 상계항변 인용판결에 대해 피고만이 항소한 경우 判 **(자배불)** (수동채권 부존재를 이유로 항소)
→ 1심판결은 부당하지만 불이익변경금지원칙상 1심판결과 이유를 같이하여 항소기각
3. 예외 **(상처직항필)**
i) **상**대방의 상소나 부대상소 ii) **처**분권주의에 의하지 않은 절차 iii) **직**권조사사항 (소송요건 흠결) iv) **항**소심에서 상계주장 인정 v) **필**공, 예공·선공, 독당

제3장 상고
<상고심 종국적 재판>
상고심 조치 (상고인용파기 or 직권파기)
(1) 환송원칙 (436)
상고이유를 인정하여 상고인용파기하거나 직권파기하는데 새롭게 사실과 증거를 조사할 필요가 있기에 자판하지 않고 환송함이 원칙
(2) 예외적 자판
1) 자판하는 경우:
437조1호, 2호, 소송요건의 흠을 이유로 원판결을 파기(判)
2) 자판의 형태
항소심의 입장에서 자판할 때, 항소에 대한 응답형태로 함.

소송종료선언: 소취하 간과, 이미 확정된 부분 심판
(객관적 병합 불복하지 않은 부분 확정 **(변직)**
독당참 상소 합일확정 필요 없는 경우 **(각항항)**
파기환송 후 항소취하 **(파항종부/부은)**)
항소각하: 항소요건 흠결
항소기각
항소인용 (1심환송, 소각하, 청구기각, 청구인용)
1심환송: 소각하-항소기각-파기자판(418)
참칭수계인 청구기각-항소기각-파기자판 (1심계속중)
소각하: 소송요건 흠결

<환송판결의 기속력>
{환송판결의 기속력 template}
1. 문제의 소재
2. 기속력의 의의·성질 (436②)
환송받은 법원이 다시 심판을 하는 경우 상고법원이 파기 이유로 한 사실상 및 법률상 판단에 기속된다. 심급제도 유지를 위해 하급심을 구속하는 특수한 효력이다.
3. 기속력의 내용
(1) 기속력의 객관적 범위 **(직절재/법사)**
1) 사실상 판단
직권조사사항, **절**차위배, **재**심사유에 관한 사실상 판단을 말하고, 본안에 관한 사실 존부 판단은 포함하지 않는다.
2) 법률상 판단
법령의 해석과 적용상의 견해, **사**실에 대한 법적평가
(2) 기속력의 주관적 범위
1) 원칙: 환송받은 법원과 하급심. 재상고법원
2) 예외: **(대환대)** "전원합의체는 종전에 **대**법원에서 판시한 법령의 해석적용에 관한 의견을 스스로 변경할 수 있는바, **환**송판결이 파기이유로 한 법률상 판단도 **대**법원에서 판시한 의견에 포함되므로 전원합의체가 변경할 수 있다"
4. 기속력의 예외 **(판사법)**
i) 환송 후 상고심의 **판**례변경, ii) 기속적 판단의 전제된 **사**실관계의 변동, iii) 환송 후 **법**령의 변경
5. 항소심판단 타당여부
(1) 파기이유 전제로 판단되는 경우 判 **(피본피논기)**
(2) 사안

제4장 항고
[결정이나 명령 고지 전에 항고제기] 判**(성고고성효/444시효/다)**

제7편【재심절차】
(재심 적법여부와 이유구비성으로 나눠 쓰는 것이 기본이지만, 재심 적법여부가 MAIN 일 때는 재심 의의 및 요건 쓰고 요건에 해당하는 것들 중목차로.)

{재심 판례 사안 template 1}
(파기환송판결에 대해 451①1호 재심의 소 제기)
1. 문제의 소재
2. 재심 의의 및 요건 (대기이사보)
대상적격, **기**간준수, 재심**이**익, 재심**사**유주장, **보**충성
3. 재심사유 451①1호 해당여부 判 **(재전법합소)**
4. 환송판결의 재심대상 적격
(1) 환송판결이 '종국'판결인지 判 "환송판결도 당해 사건에 대해 심판을 마치고 그 심급을 이탈시키는 판결이므로 종국판결"
(2) 환송판결이 '확정된' 종국판결인지
긍정설/부정설(判) **(형직실/소)**
5. 결론 - 대상적격 흠결 부적법

{재심 판례 사안 template 2}
(1차 재심청구에 451①8호 재심사유 존재하여 2차 재심의 소제기)
1. 문제의 소재
2. 재심의 소 적법여부
(1) 재심 의의 및 요건 (대기이사보)
(2) 사안 判 "재심의 소에서 확정된 종국판결도 451조 1항에서 말하는 확정된 종국판결에 해당한다."

3. 재심의 소 이유구비성
   (1) 재심사유 존재 - 451①8호
   (2) 재심판결에 재심사유 있는 경우 조치 判 **(재재본종)**
   (3) 원래확정판결에 재심사유 없는 경우 조치 判 **(종확재종)**
   (4) 사안

{재심 판례 사안 template 3}
(대표자A가 특별수권 없이 인낙한 것에 대한 준재심의 소 제기)
1. 문제의 소재
2. 준재심의 소 제기기간 적용여부 - 적극
   (1) 재심기간과 대리권 흠 456①, 457
   (2) 특별수권 흠 - 判 "특별수권을 받지 않은 경우는 3호 재심 사유에 해당하되 대리권 흠결의 경우와 달라서 457조 적용X"
   (3) 사안
3. 준재심의 소 제기기간 판단 判 **(수이다기)**

{재심 판례 사안 template 4}
(공동이해관계 없는 자 선정하고 선정당사자의 인낙에 대해
451①3호 준재심의 소 제기)
1. 문제의 소재
2. 선정당사자 C의 공동의 이해관계 존부
3. 준재심의 소에 대한 처리 - 각하
   (1) 문제점 - (대기이사보)
   (2) 학설 - 당사자적격흠결 간과한 인낙조서는 무효이므로 재심 대상적격 흠결로 부적법 각하
   (3) 判例 공동이해관계 없는 자를 선정한 사건에서, 선정당사자로서의 자격에 흠이 있지만 피고들이 스스로 선정당사자로 선정한 이상, 3호가 정한 재심사유에 해당하지 않는다고 판시.
   (4) 검토: 조서가 무효가 되는 것은 법적 안정성에 反
   (5) 사안 - 재심사유에 해당하지 않는 사유를 주장한 경우 각하